

BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Lex

DERECHO Y MORAL

RUDOLF LAUN



Ediciones
Agora

BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Carlos Alarcón Cabrera
(Director)

Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca
(Coordinadores Generales)

RUDOLF LAUN

Ex rector y profesor de la Universidad de Hamburgo

DERECHO Y MORAL

Edición al cuidado de
Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca



Título: DERECHO Y MORAL

© RUDOLF LAUN

© Ediciones Olejnik
Huérfanos 611, Santiago - Chile
E-mail: contacto@edicionesolejnik.com
Web site: <http://www.edicionesolejnik.com>

Primera edición en Ediciones Olejnik: 2020

ISBN: 978-956-392-911-9

Diseño de Carátula: Ena Zuñiga
Diagramación: Luis A. Sierra Cárdenas

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.

Impreso en Argentina 2020 Printed in Argentina

ÍNDICE

«ÉTICA», MORAL Y DERECHO
JULIO DE ZAN

1.	LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCURSO PRÁCTICO	9
1.1.	Discurso pragmático	9
1.2.	Discurso «ético»	12
1.3.	Discurso moral	17
2.	LA DEBILIDAD DE LA MORAL	22
3.	LA MEDIACIÓN DE «ÉTICA», MORAL Y DERECHO	27
4.	RAZÓN PÚBLICA Y DISCURSO JURÍDICO-POLÍTICO ...	29
5.	EL «SÍ MISMO COMO OTRO» Y LA JUSTICIA	43
	BIBLIOGRAFÍA	49
	DERECHO Y MORAL	59

«ÉTICA», MORAL Y DERECHO

1. LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCURSO PRÁCTICO

Podría decirse en sentido general que la Ética ha buscado siempre las respuestas a esta misma pregunta que se plantea el hombre en la perplejidad frente a diferentes alternativas de acción: ¿cómo debo comportarme; qué debo hacer? Pero estas preguntas mantienen todavía un significado muy impreciso mientras no se aclare cuál es el tipo de problemas prácticos que uno se plantea y bajo qué aspecto se los quiere resolver. Tres alternativas —por lo menos— se presentan para la razón práctica en su búsqueda de respuestas a las preguntas enunciadas: 1) bajo el aspecto de los resultados a lograr y de *la adecuación de los medios al fin*, 2) desde el punto de vista del hombre que es en sí bueno, o quiere serlo y desea ante todo obrar bien, cualesquiera sean los fines que se proponga y, 3) desde el punto de vista de lo correcto, o *del deber de justicia* en relación con las otras personas. Estos tres tipos de problemas son bien diferentes, requieren usos diversos de la propia razón práctica y dan lugar a otros tantos tipos de discurso, que son los que han privilegiado respectivamente los planteamientos consecuencialistas del empirismo, la ética aristotélica de la buena vida y de la virtud, y la reflexión de tipo kantiano sobre la igualdad y la reciprocidad (o la justicia) como criterio de la moralidad.¹

1.1. Discurso pragmático

Una primera clase de discursos prácticos que es preciso diferenciar son los que buscan aclarar y resolver problemas pragmáticos.

¹ Cf. J. Habermas, «Vom Pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft», en *Erläuterungen zur Diskursethik*, Fráncfort, 1991, 100-118; hay trad. española: Aclaraciones a la ética del discurso, Madrid, 2000. En este punto sigo en parte la exposición de Habermas en el citado trabajo. Las referencias dentro del texto de este apartado sin otro dato que el número de página remiten a la primera edición alemana del texto de Habermas.

Los discursos pragmáticos, en los cuales buscamos esclarecer problemas técnicos o estratégicos, son del mismo tipo y se ubican en el mismo nivel de discurso que los discursos teóricos, y su validez depende del saber empírico en el que se apoyan. Es claro que esta validez o verdad del discurso pragmático no depende además para nada del hecho de que el actor aplique o no sus indicaciones en la acción. Pero a su vez, este tipo de discurso tampoco influye directamente sobre las decisiones de la voluntad del actor, sino a través de sus fines y preferencias personales, las cuales quedan fuera de estos discursos pragmáticos.

Problemas pragmáticos se nos plantean en las situaciones en que tenemos que realizar la *elección entre diversos fines posibles, o entre los medios* para el logro del fin elegido. Así, por ejemplo, con más o menos frecuencia, según los casos, se les plantea a las personas el problema de qué hacer cuando no les alcanza el dinero para satisfacer ciertas necesidades, o para llevar a cabo determinados planes. Frente a este problema se puede presentar, según la posición social de la persona, un espectro más o menos amplio de vías o medios posibles para resolver la situación, por ejemplo: tomar un crédito, vender un bien, trabajar más duramente, o buscar otra actividad, etc. Pero al sopesar los compromisos o exigencias requeridas para obtener los medios, se vuelve a evaluar también, por lo general, si los planes o los fines propuestos guardan una proporción racional con la magnitud (o el costo) de los medios y el tiempo de trabajo que habría que invertir para lograrlos, es decir, puede cuestionarse también si vale la pena el esfuerzo que se requeriría para conseguir tales fines, y bajo este aspecto también los fines se vuelven problemáticos.

El tipo de problemas mencionado requiere un uso pragmático de la razón, el cual tiende a la determinación precisa de los datos empíricos que permiten una decisión racional. El resultado de un discurso pragmático de este tipo será entonces la recomendación de los medios más adecuados y más eficaces, del camino más seguro y más corto, o más económico, para alcanzar las metas o valores que uno desea realizar. «Se trata de la elección racional de los medios con respecto a fines ya dados, o de sopesar los fines posibles con relación a preferencias previamente aceptadas. Nuestra voluntad se encuentra ya fácticamente decidida por medio de los deseos y valores que tiene asumidos [...] Mientras la pregunta '¿qué debo hacer?'

se refiera a este tipo de tareas pragmáticas, lo que se requiere son observaciones, análisis de situación, confrontaciones y ponderación de las ventajas relativas que podemos obtener sobre la base de informaciones empíricas, desde el punto de vista de la eficiencia, o con arreglo a otras reglas de la teoría de las decisiones racionales. La reflexión práctica se mueve aquí en el horizonte de la racionalidad instrumental con arreglo a fines» (1991, p. 102).

Cuando los padres intentan aconsejar a los jóvenes, por ejemplo, acerca de la elección de una carrera o de una profesión, el discurso se centra por lo general ya en primera instancia en torno a los diversos fines posibles: ¿qué estudiar: medicina o economía...?; o más bien dedicarse al comercio, buscar un empleo, etc... Lo que se evalúa en este nivel con respecto a los fines es su *factibilidad* en relación con los medios disponibles, o su *costo* y el posible rendimiento futuro. La cuestión del «significado final para la vida», o del *valor* (en el lenguaje de Max Scheler), no puede ser planteada ni resuelta en este nivel de problematización del uso pragmático de la razón práctica. En el discurso pragmático, los fines entran en juego *como datos*, con referencia a los cuales se seleccionan los medios y se evalúa su adecuación al fin. Kant hablaba en este contexto de imperativos técnicos y pragmáticos que son reglas de destreza y sagacidad, o de prudencia. Estos son imperativos condicionados que expresan lo que «se debe» hacer en una determinada situación si uno desea lograr determinados fines. En este tipo de discurso práctico no se plantea ninguna cuestión acerca de la validez de los fines. Las cuestiones que se busca dilucidar no son cuestiones de *validez* sino conexiones de *hechos*. El utilitarismo y la teoría de las decisiones racionales han elaborado procedimientos muy refinados para resolver este tipo de problemas pragmáticos pero, como el empirismo, no conocen otro uso de la razón en el campo práctico más que éste: «como guía de nuestros juicios concernientes a causas y efectos» y como medio para corregir nuestras decisiones «cuando están basadas en una falsa suposición o elegimos medios insuficientes para el fin deseado» (D. Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, L. III, parte III, sec. III, edic. esp. de F. Duque, pp. 614-622).

El uso pragmático de la razón práctica tiene un amplio campo también fuera de los problemas de la *vida* práctica, en el ámbito de la tecnología o de la ingeniería. Como ha escrito K. Popper: «La

ingeniería social fragmentaria se parece a la ingeniería física en que considera que los *fin*es están fuera del campo de la tecnología. Todo lo que la tecnología puede decir sobre fines es si son compatibles entre sí o realizables» (Karl Popper, *La miseria del historicismo*, 1973, p. 78). Tampoco Popper reconoce o admite otro tipo de ciencia social más que esta «ingeniería social fragmentaria». «Pero, tan pronto como es la validez de los propios fines la que se ha vuelto problemática, la misma pregunta, ‘qué debo hacer’, nos remite más allá de la racionalidad instrumental conforme a fines» (1991, pp. 102-103).

1.2. Discurso «ético»

Los mismos casos que he dado como ejemplos llevan implicadas o presupuestas *decisiones* que van mucho más allá de las cuestiones meramente pragmáticas (independientemente de que el sujeto se las plantee o no como problemas). El joven que busca orientación para la elección de una profesión o una carrera, por ejemplo, no sabe a veces todavía con claridad qué es lo que quiere llegar a ser. Por eso en un primer nivel esta búsqueda tiene que tener en cuenta las propias inclinaciones y aptitudes, a partir de un mejor conocimiento de sí mismo, de qué es lo que más le gusta o despierta su interés y en qué tipo de actividad podría *realizarse mejor*. Pero si este examen se lleva más a fondo desemboca en la pregunta sobre qué *forma de vida* quisiéramos llevar, y en esto va implicado «qué persona es uno o quisiera ser». Es claro que no todas las elecciones triviales de la vida cotidiana conllevan este tipo de decisiones profundas y no pueden ser llevadas por lo tanto hasta este nivel de reflexión en el que las razones pragmáticas se evalúan (implícita o explícitamente) en el horizonte de ese otro tipo de presuposiciones valorativas que se conectan con un determinado *ethos*, pero estas opciones axiológicas profundas están implicadas o se ven comprometidas mucho más frecuentemente de lo que pensamos.

En los discursos «éticos», a diferencia del discurso pragmático, los fundamentos aportados por el discurso constituyen ya, por sí mismos, las motivaciones profundas para la determinación de las actitudes del sujeto y para sus decisiones existenciales. «No se puede realizar aquí ya, como en el caso de las recomendaciones técnicas o estratégicas, una separación entre génesis y validez [...] En los discursos ético-existenciales razón y voluntad se determinan recí-

procamente, con lo cual el discurso no puede desligarse del contexto histórico vivido que tematiza» (p. 112). Aunque no se plantean aquí pretensiones de validez universal, se puede hablar también de «discurso» en el ámbito de la «ética», por cuanto no se trata de argumentos idiosincrásicos, sino que tienen que ser comunicables y aptos para el reconocimiento intersubjetivo en el marco del mundo de la vida, o del contexto sociocultural de pertenencia de los propios sujetos, como lo pone de relieve especialmente el contextualismo.

Habermas alude en este punto a las preferencias «fuertes», como llama Charles Taylor a las valoraciones en las que se pone en juego la autocomprensión de una persona, las cuales se hallan entreteladas con la propia identidad. Las opciones existenciales de este tipo, que se fundamentan en decisiones serias acerca de valores, son las que se consideran, desde Aristóteles, como las cuestiones de la vida buena. Los estándares valorativos que los individuos aplican en este nivel no pueden comprenderse como opciones de la conciencia moral subjetiva o como preferencias puramente individuales, sino que se trata de estándares formados en el proceso de socialización dentro de un grupo y de una tradición. Por eso la autocomprensión de la identidad exige la apropiación de la propia historia de vida, así como de las tradiciones y del contexto del mundo vital que han determinado el proceso de la formación de esta identidad. Bajo este aspecto, la filosofía práctica comprende un momento hermenéutico, el cual es necesario para esclarecer el sentido del bien que forma el núcleo de la ética. En este sentido, como ha escrito H. G. Gadamer, «la gran tradición de la filosofía práctica [de Aristóteles] sigue viviendo en una hermenéutica que se hace conciente de sus implicaciones filosóficas».² Pero Habermas piensa que este esclarecimiento hermenéutico no puede ser valorativamente neutral, sino que debiera alcanzar el nivel de una «hermenéutica profunda» y capaz de autocrítica.³

En un libro anterior he presentado la concepción de la ética de Ricoeur (J. De Zan, 2002, pp. 67-88), quien renueva con método

² Cf. «Hermeneutik als praktische philosophie», en el libro de Gadamer, *Vernunft im Zeitalter der Wissenschaften*, Francfort, 1976, pp. 78 y ss.

³ Sobre este concepto de «hermenéutica racional» en Habermas, cf. nuestro trabajo anterior: «Hermenéutica y Reconstrucción racional», en Mónica Cragolini y R. Maliandi (comps.), *La razón y el minotauro*, Almagesto, Buenos Aires, 1998, pp. 301-332.

hermenéutico el planteamiento de la ética teleológica del bien, pero también integra el punto de vista moral en el sentido kantiano. En este contexto he citado también a MacIntyre como otro definido representante de la ética del bien en la filosofía contemporánea. En su libro *Tras la virtud* (Barcelona, 1987) realiza este autor un rastreo histórico de la tradición de la ética del bien en la cultura occidental, centrado en el concepto de virtud, pero al final de su investigación se ve precisado a confesar lo siguiente: «Una objeción que podría plantearse a la historia que hasta aquí he relatado es que, incluso dentro de la tradición relativamente coherente de pensamiento que he esbozado, hay demasiados conceptos de virtud diferentes e incompatibles, y no puede encontrarse unidad alguna en el concepto ni en la realidad de la historia [...] Uno de los rasgos del concepto de virtud que hasta ahora han surgido es que siempre exige la aceptación de alguna interpretación previa de ciertos rasgos de la vida moral y social, en términos de la cual tiene que definirse y explicarse [...]» (A. MacIntyre, 1987, p. 232). Esta comprobación del propio MacIntyre tiene su raíz en la *esencial historicidad y relatividad de la «ética»*, y se puede comprender como prueba de la dificultad quizás insalvable del propósito de este autor de reconstruir «un concepto unitario y central de las virtudes» mediante un método histórico.

Desde el *punto de vista «ético»*, en cuanto diferente del punto de vista moral, podría considerarse como más coherente por lo tanto la posición de R. Rorty cuando, retomando la elaboración de Wilfred Sellars afirma que: la «ética» «toma la forma de una respuesta a la pregunta '¿quiénes somos *nosotros*, cómo llegamos a ser lo que somos y qué podríamos llegar a ser?', antes que la forma de una respuesta a la pregunta '¿qué reglas deben determinar mis acciones?'. En otras palabras: la filosofía moral toma la forma de una narración [...] antes que la de una búsqueda de principios generales [...] [Y en tal sentido] el significado central de 'acción inmoral' es: 'el tipo de cosas que nosotros no hacemos' [...] Si las hace uno de nosotros, o si las hace reiteradamente, esa persona deja de ser uno de nosotros...».⁴ Esta reducción de lo moral a la perspectiva particularista del nosotros podría evaluarse, sin embargo, desde las concepciones universalistas de la moral, como una regresión al nivel de la eticidad

⁴ R. Rorty, *Contingencia, ironía y solidaridad*, Barcelona, 1991.

arcaica, etnocéntrica, premoderna, o al estadio de la conciencia moral convencional, en la terminología de Kohlberg.

Entre los autores contemporáneos que han reivindicado la «ética» como alternativa excluyente de la moral, la posición contextualista de R. Rorty deja ver más claramente que ninguna otra lo que está aquí en juego. «Podemos mantener la noción de moralidad sólo en la medida en que dejemos de concebirla como la voz de la parte divina de nosotros mismos y, en lugar de ello, la concibamos como nuestra propia voz en cuanto miembros de una comunidad, hablantes de un lenguaje común. Puedo conservar la diferencia entre moralidad y *prudencia* [esta palabra está usada aquí con el sentido de *sagacidad*] si la concibo, no como la diferencia entre una apelación a lo incondicional y una apelación a lo condicionado, sino como la diferencia entre una apelación a los intereses de nuestra comunidad y la apelación a nuestros intereses privados, posiblemente conflictivos. La importancia de este cambio está en que *hace imposible formular la pregunta: '¿Es la nuestra una sociedad moral?'* Hace imposible pensar que hay algo que se halla con respecto a mi comunidad en la misma relación en que mi comunidad se halla con respecto a mí: una comunidad más amplia llamada 'humanidad' que tenga una naturaleza intrínseca» (R. Rorty, 1991, p. 78). Dejando de lado el cuestionamiento del concepto de «naturaleza intrínseca» de la humanidad, con el que Rorty erra el tiro, porque no es lo que está planteado en la discusión poskantiana, es claro que, en rigor terminológico, el sentido de «moralidad» que Rorty acepta mantener no es la *moralidad* en el sentido de Kant, sino más bien la *eticidad* en el sentido antiguo de la «ética» de Aristóteles. Por eso me parece conceptualmente más preciso este otro texto del mismo Rorty: «Pienso que la distinción entre moralidad y prudencia, y el propio término 'moral', no son ya muy útiles. Mi pensamiento gira en torno de la habitual tesis antikantiana de que los 'principios morales' (el imperativo categórico, el principio utilitario, etc.) tienen objeto sólo en la medida en que incorporan una referencia tácita a todo un orden de instituciones, prácticas y léxicos de deliberación moral y política. Son alusiones o abreviaturas de tales prácticas, no su justificación. En el mejor de los casos constituyen un auxilio pedagógico para la incorporación de estas prácticas» (1991, p. 77).

Podría pensarse que la exclusión de la posibilidad de la pregunta por la moralidad de la propia sociedad, que he subrayado en el texto de Rorty, no es una consecuencia de su teoría sino quizás el interés inicial que lo orientaba desde el comienzo: el interés de proteger a un grupo social privilegiado, el de los blancos anglosajones de los Estados Unidos, frente a todo posible cuestionamiento moral interno o externo de sus intereses, o de sus privilegios. Pero no es esta la línea de discusión que quiero desarrollar aquí, sino la que se abre a partir de otra pregunta que Rorty ni siquiera se plantea y que también se hace imposible dentro de su posición. Esta otra pregunta la podríamos formular así: «¿Es moral la forma como yo o mi grupo social tratamos a los otros?». Podríamos preguntar todavía: «¿qué significa *moral* en esta relación?». La respuesta que quisiera evocar aquí es la que sostiene que el término «moral» alude precisamente a la relación con los *otros*, y significa o exige en esta relación fundamentalmente: *justicia y solidaridad*.⁵ La «ética» en cambio permanece centrada en el nosotros, como hemos podido comprobarlo en las expresiones de Rorty. Pero es naturalmente ciega y sorda frente a la *interpelación del otro*, que es la interpelación propiamente moral, por cuanto la relación con el otro, en sentido fuerte (otras culturas, otras identidades), no puede ya inscribirse en el contexto de «las instituciones, prácticas y léxicos» compartidos del nosotros. Frente a los extraños (a los que no pertenecen a nuestro propio círculo social y cultural), solamente quedaría en esta posición una conversación posible sobre ellos (entre los que participamos de la misma comunidad), pero no un verdadero diálogo *con* ellos; es decir, frente a los otros quedaría solamente la relación objetivante del observador externo, el uso pragmático de la razón práctica, y de los procedimientos de la acción instrumental estratégica, o las relaciones de poder.

Esta no es una derivación maliciosa que extraigo aquí de las premisas de Rorty, sino que el propio autor la explicita con el natural desparpajo que caracteriza a su lenguaje: «A menos que todos estén bastante de acuerdo en qué se considera un ser humano

⁵ Cf. J. Habermas, «Justicia y solidaridad», en: K.-O. Apel, A. Cortina, J. De Zany, D. Michelini, *Ética comunicativa y democracia*, Crítica, Barcelona, 1991; en el mismo volumen, cf. también: J. De Zan, «Significación moral de la democracia», pp. 297-320; en la misma línea puede verse el libro posterior de J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, Fráncfort, 1996 (*La inclusión del otro*, Madrid, 1999).

decente y qué no, no se puede tener una trasnochada *Gemeinschaft*. Pero se *puede* tener una sociedad civil de tipo democrático burgués. Todo lo que se necesita es la capacidad de controlar nuestros sentimientos cuando una persona radicalmente diferente se presenta en el ayuntamiento, en la verdulería o en el bazar. Cuando esto sucede, lo que hay que hacer es sonreír, hacer el mejor trato posible y, tras un esforzado regateo, retirarnos a nuestro club. Allí nos sentiremos reconfortados por la compañía de nuestros partenaires morales».⁶

1.3. Discurso moral

Las cuestiones pragmáticas referentes a los medios más eficaces para el logro de determinados fines se plantean en el marco de la relación sujeto-objeto, desde la perspectiva egocéntrica de los propios sujetos (individuales o colectivos) de la acción; en esta perspectiva *los otros* se tienen en cuenta solamente como medios, o como condiciones objetivas, cuyos intereses y posibles reacciones hay que tener en cuenta para el desarrollo de los planes de acción de cada uno en orden a la consecución de los propios fines. En los juegos de interacción estratégica los actores toman sus decisiones en base al criterio de sus propios intereses, como egoístas autointeresados. La regulación de la conflictividad siempre latente bajo tales presupuestos, la limitación de los procedimientos estratégicos permitidos en estos juegos de interacción, y el criterio para la exclusión de los medios que son moralmente inaceptables, requieren un cambio de perspectiva. «Sin un radical cambio de perspectiva y de actitud, el conflicto interpersonal no puede ser ni siquiera percibido por los participantes *en cuanto* problema moral [...] La pregunta 'qué debo hacer' cambia de sentido una vez más tan pronto mis acciones afectan los intereses de los otros y conducen a situaciones de conflicto que deben ser reguladas con imparcialidad, es decir, desde el punto de vista moral (de la justicia)» (p. 105).

Los discursos práctico-morales exigen, a diferencia de los discursos «éticos», la ruptura con todos los presupuestos y valores sobreentendidos desde los cuales acostumbramos a juzgar las cosas de la vida en nuestro círculo social y en la cultura a la cual

⁶ R. Rorty, *Objetividad, relativismo y verdad*, Barcelona, 1996, p. 283.

pertenecemos. Y como estas formas de ver y valorar las cosas son constitutivas del mundo vivido y están indisolublemente entretejidas con nuestra propia identidad, lo que se nos exige con esto es, en cierto modo, una toma de distancia con respecto a nosotros mismos. Esta difícil exigencia se plantea como una condición necesaria para alcanzar el punto de vista moral universal de la justicia como imparcialidad. A dicho objetivo apunta la hipótesis rawlsiana de la «posición originaria» y el velo de ignorancia.⁷ Pero esta construcción teórica de la reflexión filosófica no ha roto aún con el solipsismo metódico y sigue siendo insatisfactoria. «Solamente bajo las presuposiciones comunicativas de un discurso ampliado, o abierto universalmente, en el cual puedan tomar parte todos los posibles afectados (por las normas o formas de acción que se intentan justificar), se constituye la más elevada intersubjetividad del entrecruzamiento de las perspectivas de cada uno con las de todos» (p. 113).

De lo que se trata ahora, en el discurso práctico-moral, es de la fundamentación de normas que generan deberes y obligaciones recíprocas entre los individuos y los grupos, de tal manera que sean susceptibles de obtener el reconocimiento por parte de todos los afectados, como justas y aptas para la coordinación de la interacción y para la regulación imparcial de los posibles conflictos interpersonales y sociales. Tan pronto como examinamos nuestras máximas desde el punto de vista de la compatibilidad con las máximas de los otros nos aproximamos a la manera propiamente moral de considerar las cosas. (Las máximas son, sin embargo, un terreno en el que *se encuentran* la «ética» y la moral, por cuanto ellas pueden ser consideradas desde ambos puntos de vista. «En términos generales las máximas forman las unidades elementales de una red de prácticas o costumbres en las cuales se configura la identidad y el proyecto de vida de una persona o de un grupo [...] En tal sentido Kant tenía en vistas sobre todo las máximas de la naciente sociedad burguesa diferenciada en sus estamentos profesionales» (pp. 106-107). Lo cual muestra que la moral no puede nunca separarse de la «ética», aunque pretenda hacerlo, como era el caso del propio Kant, pero no ya de Habermas o de Rawls.

⁷ John Rawls, *Una teoría de la justicia*, (1971), México, 1979.

Retornando a nuestro ejemplo del comienzo de este apartado, uno puede encontrar que la manera menos costosa de resolver un problema de dinero desde el punto de vista pragmático puede ser absteniéndose del pago de algunos impuestos mediante el sencillo procedimiento de no hacer figurar en los papeles ciertas operaciones. Desde el punto de vista «ético» podría considerarse que la máxima que me autorizaría a realizar este tipo de maniobras fraudulentas *no es buena* para mí por cuanto no se corresponde con la imagen de la persona honesta que yo quisiera ser y como quisiera ser reconocido en mi comunidad. Podría considerarse también, todavía sin trascender el punto de vista «ético», que esta forma de conducta *no es buena* para los intereses de la comunidad o que es perjudicial para el bien *común*. Pero cuando los directivos de una empresa deliberan por ejemplo sobre las ventajas de la evasión o de otras estrategias de dudosa moralidad de sus sucursales en un país extranjero lejano, estos argumentos «éticos» revelan toda su insuficiencia, porque tales conductas se podrían justificar desde este punto de vista por los beneficios para la comunidad de la empresa y del país de pertenencia de quienes toman esas decisiones. Para responder desde el punto de vista moral a esta otra clase de problemas sería preciso *preguntar a todos* «si podrían aceptar que en una situación como la mía (o como la nuestra) cada cual actuara conforme a esta misma máxima de conducta», porque solamente puede ser justa, es decir moral, una máxima que sea pública y valga para todos igual. Este criterio plantea la exigencia de imparcialidad en el juicio moral, que se deriva de la igualdad de las personas y de la reciprocidad de sus derechos y obligaciones. «Solamente una máxima con aptitud de universalizabilidad desde la perspectiva de todos los afectados (es decir, de todos los que pudieren hallarse en situaciones semejantes), vale como una norma que puede obtener aceptación universal y, en cuanto tal, merece reconocimiento, es decir, es moralmente obligatoria [...] Solamente el sentido moral de este tipo de mandamientos se puede interpretar como un deber que ya no depende ni de los fines y preferencias subjetivas, ni siquiera del fin absoluto para mí de lograr el bien o la plena autorrealización de la vida» (p. 108).

Tampoco el punto de vista «ético» alcanza a plantearse esta otra clase de problemas en toda su amplitud o proyección universal que implica tratar a *los otros*, a *todos* los seres humanos como igua-

les, es decir, como personas autónomas y como fines en sí. Las cuestiones éticas se orientan en otra dirección y no exigen como tales todavía una ruptura con la perspectiva egocéntrica o etnocéntrica, que en Aristóteles estaba ligada a los que eran ciudadanos de la *polis* (helenos, varones, propietarios).

De este contextualismo etnocéntrico de la «ética» se desprende por primera vez, en un campo no filosófico, el mensaje de la religión cristiana. En la filosofía se encuentra claramente planteado sobre todo en la Ilustración moderna, y en especial a través del universalismo de la moral kantiana con la formulación del principio de la moralidad como principio de universalizabilidad de las máximas. Pero Kant pretendió expulsar de la filosofía moral los otros dos usos de la razón práctica, como formas de la razón impura, ligada a los impulsos, deseos e intereses y a las contingencias fenoménicas. El conflicto entre la moral y la «ética», que había sido ya uno de los temas más profundos de la tragedia griega, y que había cobrado en la figura de Sócrates su primera víctima filosófica, no podía ser resuelto por Kant en el marco del paradigma de la filosofía de la conciencia, que es el paradigma de la modernidad. Por eso Kant se ubica en el extremo opuesto, desplazando la filosofía práctica del campo de la «ética» enraizada en la *polis*, a la subjetividad de la conciencia y de la razón pura. Si los antiguos habían condenado la moral en la figura de Sócrates, la Ilustración y Kant condenarán la «ética» en la figura de Aristóteles. Esta incapacidad sistemática de pensar y comprender el «*mundo ético*» intersubjetivo es lo que había entrevisto ya la crítica de Hegel a la moralidad kantiana. Para encontrar el camino de la resolución de este conflicto se requería un cambio de paradigma filosófico como el que se ha operado con el giro pragmático de la filosofía contemporánea.⁸

El punto de vista moral presupone la posibilidad de trascender mediante el discurso el contexto de las prácticas, las instituciones y el lenguaje que conforman el *ethos* del grupo de pertenencia. «Tiene que haber una base común sobre la cual es posible la comprensión entre las culturas, comunidades religiosas, paradigmas y formas de vida que son extranjeras las unas *para las otras*. Es decir, tiene que

⁸ Cf. J. De Zan, «Pragmática del lenguaje y racionalidad comunicativa», en *Stromata*, XLVI, Buenos Aires, 1988, pp. 105-137.

ser posible una traducción entre los diferentes lenguajes valorativos [...] Los lenguajes tienen que ser porosos los unos para los otros, y no pueden estar de tal manera trabados en un contexto monádico cerrado e imposible de sobrepasar desde dentro, que los nativos y socializados en ese contexto queden *aprimados* en él» (p. 208). En esto ve Habermas, con J. Rawls, la diferencia entre las comprensiones del mundo tradicionales de tipo fundamentalistas, rígidamente dogmáticas, y las comprensiones del mundo que han alcanzado un grado de reflexividad compatible con la conciencia moderna. Las modernas comprensiones del mundo se diferencian por la aptitud para asumir reflexivamente la comprensión de sí mismas como propuestas alternativas que han de convivir (y competir) con otras diferentes, en el mismo universo de pretensiones de validez. La reflexividad de este saber mediante el cual las diferentes culturas, sus interpretaciones del mundo y sus sistemas de valores se sitúan a sí mismas en relación con las otras en cuanto diferentes, o la comprensión de «sí mismo como otro» (en la bella expresión de P. Ricoeur), presupone que ellas pueden confrontarse y, eventualmente, aprender las unas de las otras, porque no son universos cerrados, inconmensurables, intraducibles y absolutamente incommunicables, como quieren ciertos contextualismos.

El propio Rorty ha criticado a Lyotard cuando éste pretende apoyarse en Wittgenstein para sostener que «no existe una unidad del lenguaje sino más bien islas de lenguaje, cada una de ellas regida por un sistema de reglas intraducible al de los demás».⁹ No podríamos hablar siquiera de lenguaje con respecto a una práctica extraña y enteramente ajena a nosotros, frente a la cual hubiéramos abandonado «toda esperanza de saber cómo sería participar en ella». En este sentido, siguiendo a Davidson, sostiene Rorty que «la noción de un lenguaje intraducible al nuestro carece de significado» (R. Rorty, 1996, 290). Como explica Gadamer, la traductibilidad es definitoria de nuestro concepto de lo que es un lenguaje. El problema de Rorty es su manera de entender la comprensión y la traducción como el aprendizaje de una práctica, o «la adquisición de una habilidad» (1996, p. 291), con lo cual parecen confundirse dos cosas tan diferentes como el aprender a hablar y el problema hermenéutico

⁹ J.-Fr. Lyotard, *Tombeau de Vintelectuel*, París, 1984, p. 61.

de la comprensión y de la búsqueda del entendimiento con los hablantes de otra lengua. No obstante su propósito de reemplazar la epistemología por la hermenéutica, Rorty vuelve a anular el espacio propio del problema hermenéutico en la medida en que, según su concepción, «el fracaso en encontrar un único gran código común en el que escribir un manual universal de traducción», nos deja en la alternativa de «la necesidad de aprender constantemente nuevos lenguajes» (R. Rorty, 1996, p. 294). Con esto queda eliminado el *locus* propio de la hermenéutica, ese intersticio entre la pertenencia y la extrañeza, como decía Gadamer, en el que se despliega el diálogo con el otro. Este espacio propio de la hermenéutica, *entre la identidad y la alteridad*, es también el mismo espacio de la imparcialidad del discurso moral y de la justicia.

2. LA DEBILIDAD DE LA MORAL

Ya la axiología clásica de M. Scheler y de N. Hartmann, en su intento de fundamentar la ética en valores objetivos y universales, había señalado que la apertura intencional del espíritu a este horizonte de valores no ha de comprenderse como un impulso ontológico, como una fuerza real capaz de mover a la acción y vencer toda resistencia para orientar la vida práctica en el sentido de los valores superiores. «El espíritu *carece* originariamente de todo poderío, fuerza, actividad eficaz [...]».¹⁰ Es solamente apertura y disponibilidad para la verdad, para el bien y los valores; pura intencionalidad lógica y axiológica que descubre un sentido y señala una dirección objetiva, pero no posee por sí mismo la energía real para mover las cosas. «N. Hartmann ha expresado con mucha exactitud esta idea, que ya había definido yo en mi *Ética*; las categorías superiores del ser y del valor son por naturaleza *las más débiles* [...] originariamente lo inferior es poderoso, mientras que lo superior es impotente» (Scheler, 1964, pp. 87-88).¹¹

Los discursos morales (ya sea que tematicen la posible *fundamentación* de normas o la *aplicación* de las normas adecuadas a cada situación) son «un negocio meramente cognitivo», advierte Habermas, y no ofrecen por lo tanto ninguna compensación para la

¹⁰ M. Scheler, *El puesto del hombre en el cosmos*, Buenos Aires 1964, p. 78.

¹¹ Cf. J. De Zan, «El saber y los valores en la filosofía de Max Scheler», en *Stromata*, XXXV, n° 1-2, Buenos Aires 1979, pp. 19-60.

desconexión del juicio moral con respecto a las motivaciones *que mueven* a la acción, a *la fuerza* de las pasiones y de los impulsos vitales que ellos mismos exigen poner fuera de juego en la deliberación, como condición de la imparcialidad. La validez de los mandamientos morales es independiente del hecho de que los propios sujetos logren reunir la fuerza necesaria para cumplir lo que ellos mismos tienen que reconocer como lo correcto. Pero la voluntad llega a ser verdaderamente autónoma en la medida en que obra efectivamente conforme a la razón y a los principios morales porque únicamente entonces obedece sólo a su propia ley. Esta manera de vincular recíprocamente la autonomía de la voluntad, la racionalidad y el deber moral es característica de la ética kantiana. Esto no quiere decir, sin embargo, que los juicios morales sean capaces de producir por sí mismos un obrar efectivamente autónomo. Podría decirse incluso que Kant había confundido en cierto modo voluntad autónoma con voluntad autosuficiente (u omnipotente). Y es así como pudo pensar que era posible prescindir en la ética de las motivaciones empíricas, los intereses y los sentimientos del sujeto.

Podría pensarse que la exigencia de un punto de vista imparcial, que pretende trascender la subjetividad de la perspectiva de los participantes en el discurso, equivale a poner a la filosofía moral en la misma actitud de tercera persona, objetivante y pretendidamente neutral del saber científico. Cabría preguntarse entonces si es posible en esta materia la pretendida objetividad de un observador externo, y además, si esta actitud no cierra más bien todo acceso a la comprensión de las pretensiones de validez del mundo vivido, que es lo que se trata de comprender, de justificar o discutir en el discurso moral. Podemos estar aquí, por cierto, enteramente de acuerdo con estas objeciones. No es conforme al modelo de la relación sujeto-objeto que es posible comprender y tematizar la pretensión de validez moral, puesto que esta se plantea solamente en la relación sujeto-cosujeto de la comunicación y la interacción. El *punto de vista moral* no puede interpretarse, ni en el sentido del principio abstracto de una moral fundada en la reflexión trascendental de la pura razón al estilo kantiano, ni en la perspectiva del observador externo y de la actitud objetivante de las ciencias positivas. El juicio moral no puede ser nunca tampoco un *juicio* en el sentido del proceso judicial que presupone la existencia de un juez independiente, que no es

parte, sino aquel *ante quien* se desarrolla el proceso. En las cuestiones morales, que por definición afectan a todo hombre, el sujeto que juzga está siempre lógicamente involucrado en cuanto sujeto moral, y no puede haber juez independiente, ni un tribunal de la razón pura, situados por encima de las partes. Esta situación se aclara especialmente en el marco teórico del concepto de la *racionalidad comunicativa*, la cual se diferencia de la razón práctica, tal como fue concebida en la filosofía moderna, por el hecho de que ella no se entiende ya como el atributo o *la facultad de un sujeto*: ni del sujeto individual empírico, ni de un problemático sujeto trascendental, ni de algún macrosujeto de la historia (como fue pensado por Hegel y por Marx). La racionalidad comunicativa se constituye solamente entre los *sujetos*, en el medio o el ámbito del entendimiento intersubjetivo, a través de la cual se teje la trama de la interacción comunicativa del mundo de la vida (el *Lebenswelt*, en el sentido de la tradición fenomenológica y hermenéutica). Este horizonte de comprensión es el *lugar originario* de la racionalidad comunicativa, a partir del cual se reconstruyen las reglas y las condiciones de validez del discurso, tanto del discurso teórico, como del discurso moral. No es a partir del discurso de la ciencia o de la filosofía que se establecen las condiciones de validez o de racionalidad que se habrán de imponer al mundo de la vida, sino precisamente a la inversa.

En este contexto teórico filosófico se puede comprender ahora mejor la conexión intrínseca de la moral con la «ética», que Kant y la tradición racionalista habían desconectado, sin borrar de nuevo con esto la profunda diferencia entre ambas. Esta relación no se puede comprender ahora según el modo de una *regulación externa* de la vida «ética» por un ordenamiento formal de tipo jurídico, porque los principios morales se explicitan a partir de la reconstrucción de la forma y las condiciones de sentido y validez de la propia interacción comunicativa del mundo de la vida, y *la fuerza motivacional* de los valores del *ethos* vivido se transmite, de alguna manera, a los principios universales de la moral, porque el discurso moral no es nada más que «la continuación de la acción comunicativa con otros medios». En este sentido, la ética discursiva de Apel y de Habermas no se expone a las críticas que ha merecido la teoría de la justicia de Rawls, por ejemplo, de reproducir el abismo kantiano entre las exigencias normativas racionales construidas *in vacuo*, y la

facticidad de la realidad de la vida social. Con lo cual tiene que pagar otra vez el precio de la impotencia del puro deber. Habermas ha tomado desde el comienzo un camino diferente del construccionismo normativista kantiano. La *Teoría de la acción comunicativa* se apoya en las teorías sociológicas de la acción social y se desarrolla como una *reconstrucción* racional que explicita y potencia los elementos normativos que están ya desde siempre incorporados y operantes en los procesos reales de la interacción social. En tal sentido, como lo ha reconocido K.-O. Apel, las investigaciones de Habermas en los campos de la pragmática del lenguaje y de la acción comunicativa vienen a tender un puente entre la teoría de la acción social y el punto de vista moral de las éticas deontológicas, sin el cual la moralidad carecería de posibilidad de inserción efectiva en la estructura de la interacción humana y de la realidad social, y la ética discursiva quedaría flotando en el aire como una teoría típicamente alemana.

La moralidad universalista no podría contar de todos modos en la sociedad moderna con *las fuerzas especiales* de las motivaciones externas con que contaba la «ética» tradicional. Los fundamentos morales no reciben ya el mismo refuerzo de la presión social y cultural, ni se conectan sustantivamente con la propia identidad del sujeto en cuanto socializado en el *ethos* colectivo de donde provienen las motivaciones «éticas». Por lo tanto, deberíamos ser más bien escépticos con respecto a la fuerza motivacional de los sentimientos morales en la sociedad contemporánea. Algunos filósofos morales postanalíticos centran su expectativa en este terreno de los sentimientos morales y trabajan intensamente en el análisis del lenguaje expresivo de estos sentimientos, lo cual no es por cierto una contribución desechable, pero es claro que los sentimientos son tributarios de las convicciones, y las convicciones fuertes son las que se anudan en la *identidad* de un *ethos* vivido comunitariamente, es decir, se apoyan en la *realidad concreta* de la vida colectiva, no en la moral sino en la «ética». En tal sentido puede decirse que los *fundamentos* «éticos» de la orientación de la acción de los miembros de una comunidad (especialmente de una comunidad premoderna) provienen de la identidad constitutiva de su propio ser, son más bien *ónticos* que *lógicos*, u ontológicos. Las fundamentaciones que puede dar la moral, en cambio, no provienen del ser de la conciencia, sino de su

saber; solamente pueden hacer jugar por lo tanto, «la débil fuerza motivacional» de la *validez racional*, o del logos; no una fuerza real en sentido ontológico, sino la «fuerza espiritual» de la mera convicción que conllevan las buenas razones, la «fuerza ilocucionaria» de los buenos argumentos en cuanto tales, y la «fuerza moral» de la exigencia de fidelidad a la verdad.

La concepción clásica identificaba la razón práctica con la racionalidad «ética» vinculada a una forma de vida histórica, enraizada en un mundo cultural homogéneo, en prácticas sociales consagradas por una tradición y en un ordenamiento jurídico político que institucionalizaba esa forma de vida y sus valores sustantivos dotándolos de poder y coercitividad, por eso pretendía poder dirigir la voluntad mediante motivaciones mucho más eficaces que las que provienen de las meras razones o buenos argumentos del discurso filosófico. De ahí que A. MacIntyre no hace más que expresar su coherencia con aquella doctrina cuando se lamenta de que, para la democracia moderna, «el gobierno y la ley son o deben ser neutrales entre las concepciones rivales del buen vivir y, por ello, aunque sea tarea del gobierno promover la obediencia a la ley, según la opinión liberal, no es parte de la función legítima del gobierno el inculcar ninguna perspectiva moral [...] o exigir el ejercicio de las virtudes» (1984, p. 242). Yo creo en cambio que no es necesario declararse partidario de un individualismo liberal extremo para oponerse a la concepción del Estado paternalista que sugiere restaurar este autor, y defender como un gran logro de la modernidad la neutralidad «ética» del ordenamiento jurídico y del Estado frente a los planes de vida de los individuos, o al *ethos* de las diferentes comunidades que viven bajo su jurisdicción.

La «fuerza» de la racionalidad comunicativa «queda bajo este aspecto por detrás de las pretensiones de la razón práctica que pretendía, mediante la institución de motivaciones eficaces, dirigir la voluntad a determinados fines [...] Su normatividad conlleva solamente la débil fuerza de las motivaciones de la validez racional, que no alcanzan a garantizar por sí mismas la trasposición del discernimiento moral en las acciones concretas de los individuos» (J. Habermas 1992, p. 19). Pretender que la filosofía moral pueda tener por sí misma una fuerza motivadora capaz de determinar a la voluntad es ilusorio y peligroso. La filosofía tiene que preservarse de

semejantes pretensiones («debe guardarse de querer ser edificante», como pedía Hegel), porque ella se propone como instancia de reflexión crítica sobre todas las fuerzas motivacionales, ya sean de carácter vital, religioso, «ético»-cultural, o sociales y jurídico-políticas, de las que no podrían por cierto prescindir el hombre en la vida práctica y la sociedad, pero que requieren al mismo tiempo una instancia discursivo-racional de autorreflexión crítica y de juicio moral.

3. LA MEDIACIÓN DE «ÉTICA», MORAL Y DERECHO

Más delante sostendré que el procedimiento del discurso y las presuposiciones normativas de la argumentación o del diálogo racional se revelan como *condiciones necesarias de la intersubjetividad humana y de lo público político*, porque entran en juego en toda comunicación e interacción social, y constituyen al mismo tiempo las fuentes de las normas de una Ética mínima.¹² Pero no se pretende decir con ello que estos principios sean ya la *condición suficiente* para reconstruir toda la riqueza de contenido de una eticidad concreta capaz de orientar la vida personal y la convivencia armónica de la sociedad. También Habermas ha advertido que: «El principio de la ética del discurso se refiere a un procedimiento, es decir, a la resolución discursiva de pretensiones de validez normativa, y en cuanto tal la ética del discurso se puede caracterizar correctamente como formal. Ella no da orientaciones de contenido, sino solamente un procedimiento: el discurso práctico, el cual no es por cierto un procedimiento para la producción de los contenidos, sino para el examen de la validez de las normas propuestas. *Los discursos prácticos deben recibir por lo tanto su contenido*» (Habermas, 1983, p. 113). Este lugar originario de los contenidos valiosos del *ethos*, o de las pretensiones de validez que son tematizadas por el discurso moral, es el mundo de la vida histórica de la sociedad y de la cultura.

Podría decirse que las teorías contemporáneas de la Ética normativa han tenido en cuenta las críticas de Hegel al formalismo de la moralidad kantiana, y en tal sentido su planteamiento es postkantiano; pero el procedimiento del discurso reclama para sí también la competencia para la crítica de las pretensiones de vali-

¹² Cfr. también: A. Cortina, *Ética mínima*, Madrid, 1996. Retomo en este punto mi exposición anterior en J. De Zan, *Panorama de la ética continental contemporánea*, Akal, Madrid, 2002, p. 62-66.

dez inherentes a la «ética». El *ethos* sustancial es reconocido en esta relación solamente como punto de partida del examen crítico. Y en este último sentido la ética discursiva es también posthegeliana, y reactualiza contra Hegel el punto de vista de Kant, afirmando la superioridad del juicio moral sobre la tradición, las costumbres y las instituciones que pueden ser injustas o insensibles a ciertos derechos y a las nuevas exigencias de justicia.

Las formulaciones de Apel son bien claras con respecto a la reciprocidad de las relaciones de la interacción comunicativa del mundo de la vida «ética» y el discurso moral reflexivo: «La primacía sustantiva de las normas [mejor sería decir de los valores] del mundo de la vida, que son las que dan en la praxis el contenido al discurso moral, y el primado de la autorreflexión trascendental del discurso filosófico [en el orden de la fundamentación], no se excluyen, sino que se requieren mutuamente» (Apel, 1983, p. 415). El autor ha reaccionado por lo tanto con justificada indignación frente a las interpretaciones, que considera malintencionadas, de algunos neoaristotélicos tradicionalistas, según las cuales el universalismo racionalista de la ética del discurso 'declara como prohibido el *ethos* recibido', mientras no sea «autorizado mediante el discurso» (O. Marquard). Incluso la ética apriorista de la razón kantiana es sencillamente mal comprendida cuando se la interpreta como respuesta a la pregunta: «¿Cómo es posible la ética prescindiendo de la experiencia de la vida?», o cómo es posible la moralidad fuera del mundo «ético», porque ya la ética de Kant era más bien «una respuesta a la pregunta: ¿cómo es posible un criterio universalmente válido para el juicio moral de las diferentes y siempre cambiantes experiencias de la vida?» (Apel, 1988, pp. 160 y 163).

La reflexividad crítica del discurso moral presupone siempre los contenidos «éticos» del mundo de la vida (el *ethos*) y no puede *nunca* cuestionar *in toto* sus presuposiciones. En esto los éticos discursivos se han dejado instruir por la comprensión del círculo hermenéutico de la precomprensión, a través de Heidegger y de Gadamer. No ignoran ni rechazan el reconocimiento de este a priori de la facticidad y de la historicidad, que es como el abecé de la filosofía continental y especialmente de la tradición alemana. El discurso práctico tiene lugar por otro lado cuando se ha producido en el mundo de la vida un conflicto o el cuestionamiento de una norma previamente acep-

tada. Normalmente no es el discurso filosófico el que introduce o genera desde fuera de la praxis los cuestionamientos (aunque también puede hacerlo). La necesidad del discurso se plantea entonces como medio para volver a reconstruir los consensos quebrados y resolver los conflictos a fin de que sea posible un nuevo entendimiento intersubjetivo que permita retomar la interacción comunicativa).

La autorreflexión del discurso moral presupone por cierto una diferencia y un distanciamiento frente al mundo de la eticidad histórica objetiva, pero no se trata ya de la autorreflexión de la pura conciencia subjetiva, conforme al paradigma del solipsismo metódico, sino que se trata del discurso como institución pública del reconocimiento intersubjetivo y de la resolución racional y razonable de los desacuerdos y conflictos acerca de pretensiones de validez en las relaciones interpersonales y en la vida social en cuanto comunidad de comunicación. Los discursos prácticos se sitúan ya en el espacio público de la vida social y de las instituciones de la eticidad; en la medida en que estas últimas, a su vez, se pueden considerar también en parte (en el Estado de derecho y conforme al principio de la legitimación democrática) como realización u objetivación de pretensiones de validez objetiva reconocidas, o de consensos sociales logrados mediante anteriores discursos y renovados en la interacción comunicativa cotidiana, parece entonces que «ética» y moral no deberían ya contraponerse, sino que en la sociedad moderna tienden a compenetrarse (o al menos a *solaparse*, para emplear una expresión de Rawls), en el sentido de una institucionalización de la moralidad y de una moralización de la eticidad, sin que nunca pueda desaparecer sin embargo su diferencia, porque con ello se le quitaría el piso a la autonomía de la conciencia moral y al juicio crítico independiente.

4. RAZÓN PÚBLICA Y DISCURSO JURÍDICO-POLÍTICO

De acuerdo a todo lo expuesto, en las sociedades contemporáneas el discurso político y el discurso jurídico tienen que integrar los tres tipos de discurso práctico que se han diferenciado anteriormente, porque las condiciones de racionalidad y de razonabilidad exigen de *las decisiones políticas y judiciales*; 1) que se ajusten ante todo a los principios universales de la moral pública y a los derechos hu-

manos, y que los hagan valer, 2) que sean respetuosas de la «ética», es decir, de la forma de ser y los valores propios de las personas y de las diferentes comunidades, y 3) que sean pragmáticamente consistentes y realizables. El orden de la enumeración corresponde al orden de prioridad de las razones prácticas y de los tipos de validez que estas pretenden fundamentar: validez *moral*, «ética» y *pragmática*. La pretensión de validez específica que se juega en el discurso político, la *legitimidad*, es en lo fundamental la resultante de la integración de las tres anteriores, pero de tal manera que si alguna de ellas tiene un valor negativo, la validez política es nula. Es decir, por ejemplo, aunque una propuesta política sea muy loable desde los puntos de vista «ético» y moral, si es pragmáticamente irrealizable, carece obviamente *de toda validez* y tiene que ser desechada; si desde el punto de vista pragmático tiene todas las razones a favor y favorece el bien común colectivo, pero su implementación lesionaría los principios morales de justicia o implicaría la violación de derechos fundamentales de algunas personas, su legitimidad es cuestionable y debe ser revisada, etc.

La validez del discurso jurídico se apoya fundamentalmente en el derecho, porque puede presuponer que el derecho y las leyes han integrado, mediante los procedimientos de su producción, los resultados de discursos políticos democráticos en los que se han expuesto y sometido a crítica los puntos de vista pragmáticos de la viabilidad, se han evaluado las consecuencias o los resultados posibles de su aplicación y se han tenido en cuenta los puntos de vista «éticos» y morales, todo lo cual fundamenta su legitimidad. La filosofía del derecho se tiene que interrogar si esas importantes presuposiciones, aún cuando los procedimientos legislativos funcionaran de manera ideal, alcanzan para tener resueltos de manera automática los problemas de aplicación del derecho a cada caso particular; y si esas presuposiciones con las que trabajan en principio los jueces los eximen de un examen personal, reflexivo y crítico de la justificación racional actual y de las consecuencias futuras de la aplicación de dichos precedentes jurídicos en sus decisiones, o de su validez y aplicabilidad al caso que ellos tienen que juzgar. En el capítulo 4 volveré sobre estas cuestiones fundamentales para una ética judicial. El funcionamiento del sistema jurídico no es como el movimiento mecánico de una máquina, de la cual los jueces fueran los últi-

mos engranajes, sino que es un proceso discursivo de construcción, integración y transferencia de los diferentes tipos de validez racional (que han sido explicados más arriba como los temas de las tres clases de discurso práctico). Estos diferentes tipos de pretensiones de validez no pueden reducirse a la validez lógica formal del razonamiento, ni pueden resolverse mediante la simple aplicación de las reglas de la lógica, aunque es obvio que estas reglas tienen que ser aquí también respetadas, como en todo discurso racional. Parece entonces que, toda vez que alguna de esas pretensiones de validez y, por lo tanto, la legitimidad de los precedentes jurídicos, hayan sido seriamente cuestionadas de manera razonable, o que el propio juez haya llegado a la conclusión de que hay sólidas razones (ya sean pragmáticas, «éticas» o morales) para decidir en contrario, su responsabilidad personal le exige producir una reinterpretación o la revisión de la ley. Se comprende por lo tanto que la función del juez no puede consistir en aplicar ciegamente, como autómata, la letra de la ley sin escuchar o tener en cuenta las advertencias fundadas en buenas razones sobre, por ejemplo, las desastrosas o trágicas consecuencias sociales, culturales o económicas de una decisión, ya sea para el procesado o para la sociedad. ¿Qué es lo que espera la sociedad de la alta investidura y del gran poder que le ha otorgado: que decida sin preocuparse, o sin pensar, y sin hacerse cargo del mal, de la injusticia o del daño que va a ocasionar al procesado o a la sociedad, según sea la decisión que tome? ¿Puede un hombre o una mujer, que son juristas, eximirse de toda responsabilidad personal cuando la aplicación rutinaria y mecánica de cierta legislación compromete o lesiona, en determinadas circunstancias, derechos fundamentales de las personas? En el mencionado capítulo 3 se analizarán los distintos marcos teóricos que permiten pensar diferentes soluciones a estos problemas morales de la profesión judicial.

Conforme a las condiciones de validez de todo discurso, y teniendo en cuenta especialmente las condiciones de legitimación en el contexto político de una democracia deliberativa, el discurso político, y también el discurso jurídico (con las modalidades que corresponde), tienen que estar abiertos a las opiniones y críticas de todos los ciudadanos. Para el discurso jurídico, sin embargo, la voluntad general se presupone ya dada en lo fundamental en el derecho y las leyes legítimamente sancionadas conforme a los procedimientos de-

mocráticos. Las decisiones políticas y las leyes pueden obedecer y justificarse también (como acontece la mayoría de las veces) mediante otro tipo de «discursos» (empleando ahora este término en un sentido muy amplio) orientados a la celebración de pactos sociales que no necesitan justificarse más que como acuerdos de la voluntad de diferentes sectores sociales sobre cuestiones de interés general, y mediante negociaciones y compromisos que equilibren la puja de intereses particulares no generalizables y potencialmente conflictivos. El discurso jurídico debe permanecer ajeno y mantener su independencia frente a tales procesos de negociación política, aunque después tenga que evaluar quizás la legitimidad de sus resultados, es decir, de las decisiones políticas y legislativas. Porque las estrategias de la construcción de los consensos sociales y políticos (que incluyen juegos de poder en los que se imponen la pura sagacidad o las relaciones de fuerza, muchas veces en perjuicio de los derechos de los más débiles o de las minorías) no se legitiman tampoco por la mera facticidad de los acuerdos logrados mediante dichas negociaciones y juegos estratégicos de poder, o por la marginación del desacuerdo mediante una decisión por mayoría. *La validez o legitimidad de los resultados de estos procedimientos formales o informales del proceso político democrático, y del principio de la mayoría, está también condicionada a la racionalidad y a la razonabilidad de las condiciones pragmática, «ética» y moral de toda validez en general.* Los procedimientos de construcción política de las decisiones colectivas deben estar sometidos por lo tanto al control judicial de legitimidad desde estos puntos de vista, de los derechos y de la Constitución. Es por esta única razón que los jueces deben mantener su independencia frente a la política.

En las sociedades modernas, abiertas y pluralistas, las razones «éticas», en el sentido restringido en que esta ha sido definida aquí, no forma parte de la *razón pública*, en el sentido de Rawls. Es decir que las posiciones derivadas del *ethos* y de los valores propios de los diferentes grupos sociales, religiosos, etc., no se pueden hacer valer como argumentos positivos en el discurso político y jurídico. La moral en cambio es la condición fundamental y constitutiva de la razón pública. Ahora bien, por razones específicamente morales, la razón pública tiene por lo menos un deber negativo de respetar la inviolabilidad de las concepciones «éticas» razonables, propias de las per-

sonas y de las diferentes comunidades que forman parte de la sociedad civil. Una cuestión disputada es hasta qué punto se debe aceptar además que la mayoría instrumente al Estado y a las instituciones públicas, incluyendo a la escuela pública, para promover positivamente la hegemonía de los valores «éticos» de la propia tradición nacional. En todo caso esta afirmación positiva de la «ética» debe respetar unos límites morales precisos, que son los derechos de las minorías.

Las ideologías políticas dominantes en la modernidad, tanto en Europa como en las Américas, presuponían que el Estado moderno tenía que tener en su base un *ethos* y una cultura nacional homogénea como fundamento de su unidad y de su soberanía política. Por eso los Estados nacionales desarrollaron de manera sistemática políticas culturales y educativas con el objetivo de borrar intencionalmente las diferencias culturales existentes en la sociedad y de construir e instituir una cultura nacional como el marco identitario de la ciudadanía política. *La cuestión de la identidad ha sido una política de Estado.* El Estado moderno llevó a cabo una política de inclusión y de exclusión que ha merecido con toda razón las más fuertes críticas y que es considerada hoy como reprochable y absolutamente inaceptable en la sociedad contemporánea. La construcción política de las identidades nacionales ha llevado muchas veces, y no solamente en la Alemania de Hitler, a los programas genocidas de limpieza étnica, como el que se llevó a cabo con la llamada «conquista del desierto» en la Argentina del siglo XIX. Estas *políticas de identidad* se continuaron aplicando en nuestra sociedad casi hasta finales del siglo XX, con medios menos violentos en los períodos llamados democráticos, pero igualmente lesivos de la autonomía moral de las personas, de las diferencias de los grupos sociales y de las culturas regionales o locales.

Distintos procesos, pero sobre todo el creciente pluralismo de la sociedad civil y de la cultura actual, han contribuido finalmente a la inviabilidad y al abandono de hecho de las políticas tradicionales en el campo de la cultura y de la identidad. El desplazamiento del Estado nacional del centro de la escena ha tenido como efecto secundario la recuperación de las autonomías regionales y locales y la liberación de las identidades y de las culturas particulares que habían quedado aplastadas por la política unitaria del Estado moder-

no. Ahora se ve con claridad que, como ha escrito John Gray, «No necesitamos una misma identidad ni los mismos valores comunes para vivir juntos en paz. Lo que sí necesitamos son instituciones comunes en las que muchas formas de vida puedan coexistir». El Estado actual, ha escrito Benjamín Barber, «es como un vecindario de extranjeros».¹³ Los ciudadanos ya no pueden ni desean entenderse y sentirse unidos mediante el tipo de relaciones íntimas de la amistad ni del parentesco, como había descrito Aristóteles el vínculo «ético» constituyente de la antigua *polis*. En esta sociedad los individuos valoran sobre todo la vida privada y los espacios libres de la sociedad civil, son celosos de su independencia, de la libertad de pensamiento y de forma de vida, etc. Sin embargo, tampoco deberían tratarse con indiferencia. El hecho de vivir en el mismo país y de ser miembros de la misma sociedad política, o Estado, se podría pensar con el mencionado modelo de las relaciones entre vecinos, que tienen sus casas en la misma calle o en el mismo edificio y, si bien ninguno admite que el vecino se le meta en su propia casa para decirle cómo tiene que vivir, sin embargo están en el mismo barrio, por lo tanto, tienen muchos *intereses* comunes. Además, es de buenos vecinos interesarse por la salud del que vive enfrente, y darle una mano solidaria cuando lo necesita. En el contexto de estos cambios de la sociedad contemporánea se producen importantes corrimientos de las líneas de demarcación entre lo público y lo no público, que avanzan con velocidades muy desiguales en las diferentes sociedades y regiones del mundo, pero en todas partes se desplazan en el mismo sentido de la expansión de lo no público. ¿Qué es lo que queda entonces del proyecto (o del mito) de la modernidad sobre la comprensión omniabarcante de lo público? John Rawls ha defendido una concepción modesta, pero realista de esta idea en las condiciones de la sociedad actual y de las democracias liberales, la cual me parece muy importante, sobre todo para el discurso jurídico.

La idea de razón pública especifica al nivel más profundo los valores morales y políticos básicos [en nuestro léxico hablaríamos aquí más bien de reglas (JDZ)] que restringen las relaciones de un gobierno democrático con sus ciudadanos, y de estos en-

¹³ Benjamín Barber, «La democracia liberal y los costos del consenso», en N. Rosenblum, *El liberalismo y la vida moral*, Buenos Aires 1993, p. 72.

tre sí. Dicho en pocas palabras, concierne a cómo se ha de entender la relación política. Quienes rechazan la democracia constitucional rechazarán también obviamente la idea misma de razón pública [con sus importantes limitaciones]. Para ellos, la relación política podrá ser de amistad o de enemistad, según la pertenencia a una comunidad [en sentido fuerte], o no; o puede ser también una lucha incesante [en el sentido literal del estado de guerra] para imponer la verdad absoluta al mundo entero. Es claro que el liberalismo político no puede atraer a quienes piensan así (Rawls, 2001, p. 157).

La idea de razón pública de Rawls presenta un núcleo simple e intuitivamente plausible. Su desarrollo es bastante complejo y cuestionable en diversos aspectos, pero no podré entrar ahora en esa discusión. Me limitaré a rescatar aquí el núcleo aproblemático de la idea. Rawls explica su idea de esta manera: todo agente racional y razonable, individual o colectivo, se fija un plan y una meta para sus actividades en el campo en el que está comprometido. El modo en que delibera en el marco de esos presupuestos son sus razones particulares. La razón pública es tal en cuanto 1) es la razón del público, o de los ciudadanos en general y en cuanto tales; 2) la finalidad que se busca en el ejercicio de la razón pública es el bien general o la satisfacción de un interés público. La existencia y el funcionamiento posible de una razón público-política se vinculan solamente con aquellos intereses que son comunes a todos. Presupone además que hay un acuerdo de los ciudadanos en la validez moral de los principios de justicia, en el mantenimiento de un orden constitucional aceptado y legitimado en cuanto institucionaliza dichos principios, e incluso un compromiso de cooperación en la busca del bien común. Los individuos saben al mismo tiempo que también están divididos por intereses divergentes, por creencias o concepciones comprensivas del mundo y de la vida, ideales «éticos», religiosos, etc., que no pueden compartir con todos los demás. La razón pública es precisamente entonces la capacidad de los ciudadanos de explicarse unos a otros los fundamentos de su aceptación del orden constitucional común y de los principios que lo inspiran, y de justificar sus propias preferencias y acciones políticas, sin apelar a sus particulares creencias y concepciones del mundo y de la vida (filosóficas, «éticas», religiosas, etc.) sino mediante razones tales que

puedan tener una adecuada comprensibilidad y eventual aceptabilidad para cualquier otro ciudadano, es decir, que puedan ser apoyadas o discutidas con argumentos que pueden desplegarse y apoyarse en un terreno común a todas las personas razonables. Este es precisamente el tipo de las razones públicas. Hay muchas razones no públicas, pero una sola razón pública. Las primeras no se pueden hacer valer en el espacio público y en el discurso político de una democracia pluralista como razones para fundamentar decisiones colectivas que involucran a todos los ciudadanos. Esto no debe interpretarse en el sentido de una restricción de la libertad de expresión y del derecho de las personas y de las comunidades religiosas, por ejemplo, a declarar, proponer y defender, o difundir públicamente sus creencias y valores.

[Las restricciones de la idea de razón pública] no se aplican a todos los debates políticos sobre cuestiones fundamentales, sino a aquellas cuestiones que caen dentro de lo que propongo llamar foro público. Este foro se puede dividir en tres partes: el discurso de los jueces en sus decisiones y, en especial, el de los magistrados en el Tribunal Supremo; el discurso de los funcionarios públicos y, en especial, el de los altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo; y finalmente el discurso de los candidatos a los cargos públicos [...] La idea de la razón pública no se aplica de la misma manera en estos casos y en otros [...] se aplica de manera más estricta a los jueces que a otros, pero las exigencias de justificación pública de esta razón son siempre las mismas para todos (Rawls, 2001, p. 158).

La razón pública rige de un modo especial para el Poder Judicial, sobre todo para un tribunal en una democracia con poder de revisión judicial. Esto se debe a que los jueces tienen que explicar y justificar sus decisiones fundándolas en su interpretación de la Constitución y de las leyes antecedentes y relevantes [...] El especial papel de los tribunales de justicia los convierte en el paradigma de la razón pública [...] La razón pública es la única razón de que se vale el tribunal. Él es la única rama del Estado que es palmaria y visiblemente criatura de la razón, y sólo de tal razón. Los ciudadanos y los legisladores pueden votar de acuerdo con sus respectivas doctrinas comprensivas, más abarcadoras [...] y no necesitan justificar mediante la razón

porqué han votado como lo hicieron [...] Pero el papel de los jueces consiste precisamente en hacer eso, y al hacerlo no pueden exponer otra razón que la pública, ni otros valores que los de la razón pública-política, es decir, los principios de justicia del derecho y de la Constitución (Rawls, 1996, pp. 250-251 y 270-271).

Rawls propone dos restricciones fundamentales a la idea de razón pública. La primera se refiere a los temas que pueden ser sometidos a una decisión pública vinculante. Sobre este aspecto no necesito agregar nada aquí, porque esta demarcación es la que he tratado ampliamente en los apartados precedentes mediante la distinción de la «ética» y la moral, aunque el propio Rawls usa otro lenguaje, el de su propia teoría de la justicia. El único tema de la razón pública «es el bien público referente a cuestiones de justicia política fundamental, es decir, cuestiones esenciales de justicia básica», tal como se definen en *El liberalismo político*, VI, 5. El motivo de esta restricción es claro: porque se supone que en estas cuestiones de los principios constitucionales es posible un acuerdo democrático aún en una sociedad que se hace cada vez más pluralista, siempre que todos estén dispuestos a poner en juego en este debate solamente razones públicas, es decir, independientes de los presupuestos teóricos y «éticos» de sus concepciones del mundo y de la vida. Una objeción que se puede hacer a esta demarcación de los contenidos de la razón pública es que parece identificar lo público-político con los contenidos del discurso jurídico. Los temas de la razón pública rawlsiana son importantes para diseñar el marco jurídico constitucional en el cual se pueden desarrollar los debates y las «luchas» político-sociales de la democracia, como las luchas por la inclusión social y el reconocimiento de los derechos, la competencia de los proyectos políticos rivales, las negociaciones entre intereses sectoriales o regionales conflictivos, etc. Las preguntas que tengo que dejar pendientes aquí son si este concepto de la razón pública no deja fuera de juego todo el campo de la política propiamente dicha, y cómo se articula este campo con la razón pública. No estoy seguro de si el propio Rawls tenía una respuesta para estas preguntas.

La exclusión de las cuestiones «éticas» sustantivas del *foro público* no implica desconocer sin embargo *el uso de la razón práctica en la «ética»* o considerar estas cuestiones como no racionales. A

diferencia de lo que pensaron Kierkegaard y Wittgenstein (y siguen sosteniendo sus respectivos epígonos) yo creo que puede admitirse, con los comunitaristas como Ch. Taylor y A. MacIntyre, la posibilidad de un *discurso* «ético» diferente del discurso moral, pero que es más que una mera conversación privada en el sentido de Rorty. Aunque las pretensiones de validez que se dirimen en *los discursos éticos* no sean universalizables, se puede hablar también de *discurso* en la «ética» por cuanto no se trata de meros sentimientos, de intuiciones emocionales en el sentido de M. Scheler, o de preferencias idiosincrásicas, sino de valores comunicables y aptos para el reconocimiento intersubjetivo en el marco de un mundo de la vida, o de los contextos socioculturales de pertenencia. Pero estos discursos «éticos» sobre valores y modelos de vida se apoyan en presupuestos que pertenecen a un determinado *Lebenswelt* o que son reconocidos solamente en las comunidades particulares, a las que libremente hemos adherido. Lo que no puede aceptarse en las sociedades modernas, respetuosas de la pluralidad y las diferencias de las convicciones e ideales de vida, es que los contenidos sustantivos de las razones «éticas» pretendan hacerse valer en la esfera pública como universales. El pluralismo ético de las motivaciones del vivir no podría suprimirse sin lesionar nuestro sentido moderno de la libertad. Y no puede concebirse y mantenerse este pluralismo sin aceptar al mismo tiempo la inviolable privacidad de las convicciones «éticas» y de la libertad de conciencia. Esta comprensión viene a coincidir en este aspecto con la de R. Rorty cuando dice que él intenta «mostrar el aspecto que cobran las cosas si excluimos la exigencia de una teoría que unifique lo público y lo privado y nos contentamos con tratar las exigencias de creación de sí mismo y de solidaridad humana como igualmente válidas, aunque definitivamente inconmensurables» (R. Rorty, 1991). La restricción de los contenidos de la razón pública se refiere precisamente a «la aplicación de estas concepciones en los debates sobre normas coercitivas que se convierten en leyes legítimas de una sociedad democrática» (Rawls, 2001, p. 157).

Las cuestiones éticas, como la cuestión central, de sentido aristotélico, que MacIntyre considera fundante del concepto de virtud, acerca del «telos que constituye el bien de la vida humana completa concebida como unidad», etc., son cuestiones que sola-

mente admiten discusión y perspectivas de entendimiento en ámbitos particulares, libremente elegidos y recortados por los propios miembros de una comunidad de vida. En el contexto de la fractura de las grandes identidades colectivas y del multiculturalismo de la sociedad moderna parece que la «ética» se ha privatizado de manera irreparable. No sería correcto sin embargo hablar de la ética como un asunto meramente privado. Ello equivaldría a decir que en este ámbito ya no es posible ningún discurso, porque es claro después de Wittgenstein que no puede haber un lenguaje privado, y menos aún entonces un discurso privado. También J. Rawls se ha planteado este mismo problema y ha intentado no solamente conectar lo que él llama la razón pública con las razones no públicas de los diferentes grupos humanos, asociaciones e instituciones de la sociedad civil, sino mostrar como ellas se entrecruzan y pueden constituir un *overlapping consensus*, que se requiere para estabilizar la estructura básica constitucional de una sociedad bien ordenada.¹⁴ Por eso es además importante remarcar que: «La distinción de público versus no público no coincide aquí con la distinción entre público y privado, porque no hay algo así como una razón privada» (J. Rawls, 1996, p. 255).

Es preciso advertir además que la restricción de los temas o cuestiones marcada por este autor se refiere específicamente al «foro

¹⁴ La expresión de Rawls se ha traducido como «consenso entrecruzado»; se entiende con ello el acuerdo de los ciudadanos y los diversos grupos sociales y el apoyo que le prestan a las instituciones de la democracia liberal y a la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. No obstante las profundas diferencias de las doctrinas comprensivas (es decir de las convicciones filosóficas, éticas y religiosas, etc.), del trasfondo cultural y de las formas de vida de los grupos sociales, cada uno conecta y refuerza la fundamentación de los valores de la democracia y de los derechos humanos con los valores sustantivos de sus propias creencias, o con los recursos simbólicos de su cultura de base, y todos convergen en apoyar la estructura básica de la misma sociedad, aunque por razones o motivos diferentes. El consenso entrecruzado se funda también, sin embargo, en una doble exclusión: 1) se excluyen del discurso público las razones derivadas de las propias doctrinas comprensivas, 2) se excluyen del espacio mismo del discurso las doctrinas comprensivas no razonables. Lo que no encuentro aclarado en este autor es quién toma la decisión de estas exclusiones y cuál es el procedimiento para decidirlas. Este es un blanco de fuertes críticas al liberalismo político como un decisionismo encubierto, cf. Ch. Mouffe, «Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal», en *Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe*, n° 10, 2002, pp. 5-25.

público», que tiene un carácter institucional, estatal o paraestatal. De todos modos, la razón pública es una cosa demasiado importante para hacer de ella la razón de un foro especial y ligado al sistema de poder administrativo del Estado. La mayoría de los autores que han tratado estos asuntos hablan en cambio de «el espacio público». Esta expresión resulta hoy sin embargo muy ambigua, porque en la teoría política anterior el espacio público era concebido como un espacio unificado y como el lugar propio de lo político, centrado en el Estado. En la teoría política más actual se suele emplear más bien en plural la expresión «los espacios públicos de la sociedad civil», los cuales no son espacios meramente políticos, pero naturalmente son (de manera deliberada o no) *también políticos*. Y en una democracia deliberativa son los lugares fundamentales de la constitución de la opinión pública y del poder comunicativo, es decir, de lo político, en el que se apoya el sistema institucional y el poder administrativo del Estado. Está claro que los *discursos públicos* no tienen ninguna clase de restricciones temáticas en los espacios públicos así comprendidos, tampoco para Rawls, aunque él no haya empleado esta última expresión.

La otra restricción de la idea de razón pública en Rawls se refiere a los sujetos de la misma, los cuales están especificados en el párrafo citado más arriba. Me interesaba aquí especialmente ese texto por el significado paradigmático que le asigna el autor al lenguaje de los jueces para la definición de la idea misma de razón pública y porque, recíprocamente, propone una definición de la función judicial a partir de esta idea. Pero cabe preguntar si para el autor los jueces, legisladores y otros funcionarios son los únicos sujetos reconocidos y autorizados para hacer uso de la razón pública. El texto de Rawls tiene que ser releído e interpretado en el contexto del libro del que ha sido extractado, y de su teoría política. Creo que está claro que esta restricción tiene que ser comprendida en el sentido negativo de que estos sujetos solamente pueden recurrir para la fundamentación o justificación de sus decisiones oficiales a la razón pública, excluyendo toda otra clase de razones o motivos. Pero no que estos sujetos tengan el monopolio de la razón pública, porque «dicha razón es pública en primer lugar como razón de los ciudadanos libres e iguales, es decir: como la razón del público», y su aplicación debe estar sometida «al control ciudadano para que los

principios derivados de aquellas concepciones de justicia [en las que se basa la razón pública] satisfagan el criterio de reciprocidad» (Rawls, 2001, p. 156).¹⁵

Después de la quiebra del socialismo de Estado se puede ver más claramente que nunca que el error teórico fundamental del llamado socialismo real fue confundir el significado normativo de las ideas socialistas con la construcción y la imposición de un modelo de organización social rígidamente regimentado como una «forma de vida» planificada y sancionada con fuerza de obligatoriedad «ética» y jurídica para toda la sociedad. El fracaso de esta manera de concebir el socialismo y las desviaciones caricaturescas, por no decir macabras, de la práctica con respecto a los propios valores y a la «ética» en que se inspiraba, es el experimento moderno más instructivo de la inviabilidad histórica de *cualquier* proyecto «ético» colectivo en las condiciones de las grandes sociedades complejas y de los Estados modernos, por más nobles que sean los valores que se tratan de encarnar. Ese es el destino manifiesto de todo proyecto de restauración de una «ética» vinculante para toda la sociedad, sea de derecha o de izquierda. El error no está en el ala en que uno se ubique, sino en el corazón de esta clase de proyectos.

Sin embargo, el mayor riesgo de la sociedad occidental contemporánea no es ya el de la instalación de algún modelo constrictivo, cohesionado por fuertes motivaciones colectivas, sino la disolución de toda eticidad comunitaria, aun en las esferas de la vida privada, por el avance de la «colonización interna del mundo vivido» por parte de la racionalidad puramente instrumental y estratégica de los juegos competitivos del mercado o del poder burocrático gerencial. En este aspecto es preciso atender a las críticas comunitaristas de las democracias liberales en cuanto «formadas por individuos con proyectos orientados en su concepción del bien [o del interés] propio, pero sin ninguna concepción del bien sostenida en común y defendida por la sociedad misma. Esta parece ser la fórmula de una sociedad instrumental, que excluye por completo la forma republicana como una empresa común con la que se identifican los ciudada-

¹⁵ Confrontar esta comprensión de las restricciones rawlsianas de la idea de razón pública con la del Prof. Osvaldo Guariglia, *Una ética para el siglo XXI. Ética y derechos humanos en un tiempo posmetafísico*, FCE, Buenos Aires, 2002, pp. 140-155. Si no lo interpreto mal, su lectura es diferente.

nos, en la que el lazo de solidaridad conlleva el sentimiento de un destino compartido y donde el hecho de compartir tiene valor por sí mismo».¹⁶ Pero los comunitaristas más conservadores consideran que el cierre cada vez más asfixiante de la «jaula de hierro» de la racionalidad instrumental weberiana tiene su raíz en el politeísmo de los valores de la modernidad, el cual ha fragmentado a la comunidad y ha debilitado o anulado su capacidad de resistencia. Y por lo tanto la lucha de los neoconservadores fuertes se verá llevada a atacar ante todo la raíz del problema. Será una lucha cultural contra aquel politeísmo, es decir, contra el pluralismo de la sociedad moderna. Rawls y los filósofos del liberalismo político, en cambio, piensan que el pluralismo ha venido para quedarse en la sociedad, y que tiene que considerarse como un progreso de la libertad (el cual puede favorecer y estimular incluso la autenticidad y la vitalidad propia del *ethos* de las comunidades). Habermas apela precisamente a la pluralidad de los espacios públicos, de las iniciativas informales de la sociedad civil y de los movimientos sociales, como la instancia desde donde es posible pensar en un control democrático de la racionalidad estratégica y burocrática, en una recuperación de lo político y en el ejercicio de la ciudadanía como fuente del poder comunicativo de una democracia deliberativa. En su teoría de la democracia deliberativa él pretende rescatar de la idea del socialismo el proyecto y las condiciones necesarias de las formas de vida emancipadas, sobre las cuales son los propios participantes quienes tienen que ponerse de acuerdo. Pero al mismo tiempo cree posible reconstruir ese proyecto como el núcleo normativo de la auto-organización democrática de una sociedad abierta, constituida como Estado de derecho.

La idea de la democracia deliberativa y del papel político protagónico de la sociedad civil no deriva en el anarquismo, ni en las utopías de la anulación de las mediaciones representativas y de la democracia directa. El pluralismo, la fragmentación y la complejidad de la sociedad contemporánea aleja más que nunca la posibilidad de pensar esas ideas utópicas. La construcción de los consensos sociales y la generación de poder político comunicativo tienen

¹⁶ Charles Taylor, «Propósitos cruzados: el debate liberal-comunitario», en R. Rosenblum, o. cit., pp. 187-189.

que poder canalizarse a su vez a través de las vías institucionales, jurídico-políticas. «La constitución de la forma del derecho [su coactividad respaldada en la fuerza del Estado] se torna necesaria para compensar las deficiencias [de cohesión y normalidad social] que se producen con la caída de la eticidad tradicional. Por cuanto la moral autónoma, apoyada solamente en los fundamentos racionales, alcanza para respaldar únicamente el juicio [pero no las conductas de los individuos y la forma de ser de la sociedad]. Con el pasaje al nivel de la fundamentación posconvencional la conciencia moral se desprende de la praxis tradicional en la que se había formado [...]» (Habermas, 1992, p. 145). En esta situación se hace especialmente necesaria la *compensación* de la debilidad práctica de una moralidad racional, que se actualiza como una forma de saber, y su complementación mediante el derecho, si bien la juridización de la moral tiene que ser muy austera o limitada, y mantener especialmente su independencia de la «ética».

5. EL «SÍ MISMO COMO OTRO» Y LA JUSTICIA

Otra comprensión de los mismos problemas tratados en este capítulo, que enriquece y complementa los puntos de vista de los autores trabajados en los puntos anteriores, es la que podemos encontrar en Paul Ricoeur. La extraña expresión *sí mismo como otro* está tomada del título de uno de los últimos libros de Ricoeur, *Soi-même comme un autre*, de 1990.¹⁷ Este título tiene la intención filosófica de disociar los dos significados de «identidad», según que se la entienda a partir de las palabra latina «idem», de la que deriva el término castellano, o de la palabra «ipse» que se traduce precisamente como «sí mismo» y denota otro nivel y otro significado de la identidad. La identidad *idem* connota ante todo permanencia siempre igual, sin modificaciones en el tiempo. Uno sigue siendo idéntico en cuanto sigue siendo igual que antes, es decir, en cuanto no ha cambiado y permanece en algún sentido inalterable. La tesis de Ricoeur será precisamente que la identidad en el sentido de *ipse* (o la ipseidad) tiene un sentido más profundo, pero «no implica sin embargo ninguna afirmación sobre un pretendido núcleo inalterable de la personalidad» (*o. cit.*, XIII). La expresión «sí mismo», a diferencia de *idem*, presupone

¹⁷ Paul Ricoeur, *Sí mismo como otro*, México, 1996.

además una cierta relación dialéctica de *mismidad* y *alteridad*, del sí con otros, o frente a otros.

Ricoeur nos propone reflexionar sobre la diferencia de dos modelos de identificación y de permanencia en el tiempo que están subyacentes al hablar de nosotros mismos y que se pueden distinguir mediante estos dos términos, «a la vez descriptivos y emblemáticos: el *carácter* y la *palabra dada*» (1996, p. 112). Los rasgos del carácter permiten identificar al individuo como siendo el mismo a través del tiempo, no sólo numéricamente sino también cualitativamente. Esta identidad del carácter proviene del nacimiento, forma parte de lo involuntario de mi ser, no es elegida, pero tiene que ser asumida como una condición de la finitud humana. (Sobre este aspecto remite el autor a otro libro suyo, *Le volontaire et l'involontaire*, 1950). El carácter es en parte herencia natural y en parte herencia de la cultura, adquirida al crecer en una comunidad con determinados valores, costumbres y forma de ser. Bajo este último aspecto el que uno siga siendo el mismo (*idem*) depende también de la lealtad o fidelidad a su origen. Pero en otro aspecto, según piensa Ricoeur, este modelo de la identidad como permanencia del carácter conlleva el ocultamiento de la problemática de la diferencia del *idem* y el *ipse*.

Este «ocultamiento» del que habla Ricoeur, es el que tiene lugar, me parece, por ejemplo, en A. MacIntyre, en quien se borra la diferencia de los dos modelos de la identidad: «Soy hijo o hija de alguien [...] ciudadano de esta o aquella ciudad, miembro de este o aquel gremio o profesión [...] Como tal heredo del pasado de mi familia, mi ciudad, mi tribu, mi nación, una variedad de deberes, herencias, expectativas correctas y obligaciones. Ellas constituyen los datos previos de mi vida, mi punto de partida moral. Estas ideas posiblemente parezcan extrañas e incluso sorprendentes desde el punto de vista del individualismo moderno, según el cual yo soy lo que haya escogido ser, y siempre puedo, si quiero, poner en cuestión lo que aparece como meros rasgos sociales contingentes de mi existencia [...] Según el punto de vista narrativo del yo, sin embargo, la historia de mi vida está siempre embebida en la de aquellas comunidades de las que derivo mi identidad. He nacido de un pasado, e intentar desgajarme de ese pasado de manera individualista es deformar mis relaciones presentes. La posesión de

una identidad histórica y la posesión de una identidad social coinciden. Tengamos presente que la rebelión contra mi identidad es siempre también un modo posible de expresarla» (*Tras la virtud*, Barcelona, 1984, pp. 271-272).

El otro modelo de identificación, que Ricoeur se esfuerza por diferenciar de ese determinismo del origen que encontramos en la imagen nostálgica de la sociedad tradicional transmitida por MacIntyre, es el modelo de la fidelidad a las libres elecciones de la voluntad; el mantenimiento de la palabra dada, el cual pone de relieve la diferencia de la identidad como ipseidad frente a la mera permanencia del carácter. «El cumplimiento de la promesa parece constituir un desafío al tiempo, una negación del cambio: [el prometer es asegurar que] aunque cambie mi deseo, aunque yo cambie de opinión, de inclinación [de profesión], ‘yo me mantendré’ [en la promesa dada].¹⁸ Basta por sí misma la justificación propiamente ética de la promesa que está implicada en la obligación de salvaguardar la institución del lenguaje y de responder a la confianza que el otro ha depositado en mi fidelidad» (Ricoeur, 1996, p. 119). Este segundo modelo de la identidad es más capaz de vencer la contingencia del tiempo; es más fuerte y más significativo que la terquedad del carácter.

La diferencia entre la permanencia del carácter y el mantenimiento de la palabra como dos modelos de la identidad personal se conecta también esencialmente con la diferencia entre la ética y la moral; aunque el propio Ricoeur no explicita esta conexión, basta recordar el significado especial de la promesa en Kant como el más claro ejemplo de los deberes estrictos conforme al criterio de universalizabilidad de la ley moral. Por lo tanto, podríamos decir que su propia concepción fundamental en este libro no está centrada en la identidad del *ethos* (que está en el plano del carácter), sino en la identidad moral de la persona.

En el centro y en lo más profundo de la intención ética de la vida buena cree encontrar Ricoeur la actitud y el sentimiento de la

¹⁸ El título del libro de A. Garapon sobre los jueces es, precisamente: *Le Gardien des promesses* (El guardián de las promesas). Hay en esta expresión una clara resonancia del pensamiento de Ricoeur, la cual se ha perdido lamentablemente en la traducción española que ha suprimido esa bella expresión, y titula: *Juez y democracia*, Madrid, 1997.

estima de sí, la solicitud por el otro y la percepción de sí mismo como un otro con los otros. La solicitud por el otro no se agrega desde afuera de la estima de sí, sino que está ya implícita en ella, y sólo se requiere un trabajo de análisis fenomenológico para descubrirla como el despliegue de la esencial dimensión dialógica del sí mismo. La instancia de la alteridad es insoslayable y constitutiva de la propia identidad narrativa (dime con quién andas y te diré quién eres). Ninguna historia de vida humana es solipsista y monológica, sino que está esencialmente entretrejida con las otras historias con las cuales cada sí mismo está involucrado desde el nacimiento y se va comprometiendo hasta la muerte. La presencia y el acogimiento del otro, antes de ser un imperativo moral, es un constitutivo ontológico de la persona.¹⁹ El sí mismo solamente llega a ser sí mismo y quien es por la mediación de la alteridad y el reconocimiento recíproco con el otro. Ya al realizar el primer acto de habla se dirige a un otro y no puede comenzar a decir yo sin presuponer el tú.

El sentido de justicia es para Ricoeur una ampliación de la dialéctica de la estima de sí y la solicitud por el otro, que se prolonga más allá de la relación interpersonal, cara a cara, en el plano de las instituciones y de la vida política donde el otro es «el cada uno sin rostro» que reclama una justa distribución de las cargas y beneficios de la vida en común, en la institución. Ya Levinas había señalado este camino: a través del rostro de este otro concreto se me revela «él», la tercera persona, es decir, *todo otro* hombre. Y en esta dimensión ampliada del tercero, el otro sin rostro, se plantean las relaciones institucionales de justicia. Por institución entiende Ricoeur «las estructuras *del vivir juntos* de una comunidad histórica». El fundamento de las instituciones de la vida en común no está, para Ricoeur, como para Aristóteles, en las reglas coactivas que fijan deberes y derechos, sino que la institucionalidad tiene su origen ante todo en la voluntad de vivir juntos, y se consolida mediante costumbres y sentimientos compartidos que configuran un *ethos* común a sus miembros. Es decir que tiene una raíz ética antes que moral o jurídica, aunque luego requiera también

¹⁹ Cf. A. Fornari, en J. De Zan y otros, «Los fundamentos de la ética en la época contemporánea. Problemas y propuestas», *Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe*, n° 3, 1995, pp. 123-124.

del apoyo de las normas. El sentido de la justicia emerge de la ética, del querer vivir juntos una vida buena, y no del punto de vista moral, de la prohibición y del sistema jurídico, aunque allí tendrá la formalización que confiere a las instituciones la coherencia y la protección que les permite adquirir estabilidad y perdurar en el tiempo.

En este punto recupera Ricoeur el concepto del poder, de Hannah Arendt, como opuesto a la violencia o a la fuerza y como resultado del querer vivir juntos y de la acción en común, o de la *praxis* (no *poiesis*), en el sentido de Aristóteles. A partir de estas fuentes de pensamiento quiero agregar que este lugar originario del poder que se transfiere luego a las instituciones y al orden político, un poder que no es «violencia legítima» (expresión contradictoria, que M. Weber transmitió con éxito lamentable a la ciencia política contemporánea), permanece de ordinario *invisible* y se haya encubierto por las estructuras institucionales y las relaciones de dominación. (Habermas diferencia en este sentido *la génesis comunicativa del uso administrativo del poder*). Pero el estrato visible solamente existe y se mantiene sin apelar a la violencia mientras logra conectar con aquella base y canalizar algo de la fuente genuina del poder democrático. Esta fuente sólo se hace visible y sube al centro del escenario político de manera discontinua, en situaciones excepcionales, en los momentos fundacionales de las comunidades y de los Estados, en las circunstancias de crispación política en que el pueblo se vuelca disruptivamente a las calles para decir que no, y en «el caso serio» de las situaciones revolucionarias, en las que la irrupción del descontento de la multitud disuelve y barre todo un orden institucional jurídico-político que se ha desconectado de su fuente del poder, se ha tornado ilegítimo y se sostiene solamente por la fuerza, porque ha devenido, a la vez, impotente e injusto.

El genuino poder que legitima y sostiene el vigor del poder administrativo de los gobernantes y de las instituciones, es al mismo tiempo la fuente del cuestionamiento que les sustrae ese poder, las desestabiliza y, finalmente, las hace caer toda vez que estas se desconectan de su base constitutiva y distorsionan o traicionan la intención ética más profunda de la institucionalidad de la vida en común. Lo novedoso de esta apropiación del pensamiento arendtiano

sobre el poder por parte de Ricoeur, es que él ha puesto en esta base profunda y anterior a las instituciones y a sus formas jurídicas la raíz del sentido de la justicia y del reclamo de justicia como una exigencia ética, antes que jurídica y política. Y por esta vía intentará proveer a las teorías de la justicia, como la de Rawls, de otro fundamento independiente, más profundo y más potente que el del construccionismo racional y contractualista. «Por evasivo que sea el poder en su estructura fundamental; por débil que él sea sin la ayuda de una autoridad que lo articule en sus fundamentos más antiguos, es él, en cuanto querer obrar y vivir juntos, el que aporta a la intención ética el punto de aplicación de su tercera dimensión indispensable, *la justicia*» (Ricoeur, 1996, p. 230).

La justicia como la primera virtud de las instituciones es la intención ética que tiende a poner la dominación política bajo la dirección y el control del poder social. Esta tarea podría caracterizar el proyecto definitorio de la democracia. Pero es sin embargo una tarea siempre inacabada, y «nada es más grave como el confundir el poder con la dominación [...] si el poder es la fuente olvidada de la dominación [...] es incontestable la ausencia de paralelismo entre la autonomía moral y lo que sería para un pueblo la autolegislación mediante la cual la dominación no haría más que arrancar del olvido el querer vivir juntos y el actuar en común de un pueblo» (Ricoeur, 1996, p. 283). Ricoeur se separa con esto de la utopía democrática en la cual la dominación se suprimiría como tal para dar lugar al puro poder inmanente a la praxis, en el sentido de H. Arendt. El propio Kant, influenciado por Rousseau, había sostenido que: «El poder legislativo sólo puede corresponderle a la voluntad unificada de todo el pueblo, de quien debe emanar todo derecho [...] Por consiguiente sólo puede ser legisladora la voluntad consensuada y unificada de todos» (*Doctrina del derecho*, § 46). La crítica liberal ha insistido, como se sabe, en que este concepto de la voluntad unificada del pueblo es una ficción que sólo podría realizarse suprimiendo las diferencias y la heterogeneidad de las voluntades individuales. Es claro que la posición de Ricoeur tiene en cuenta este tipo de críticas y por eso contradice la propuesta rousseauiana de H. Arendt. Pero esta es una discusión abierta, y sin dudas fundamental, en la filosofía política contemporánea, en la que ya no podré entrar ahora.

BIBLIOGRAFÍA

- AGAMBEN, Giorgio, *La comunidad que viene*, Pretextos, 1999.
- ALEXY, Robert, *Theorie der Juristischen Argumentation*, Fráncfort, 1978 (trad. esp.: *Teoría de la argumentación jurídica*, Madrid, 1989).
- *Teoría del discurso y derechos humanos*, Colombia, 1995.
- APEL, Karl-Otto, *Transformación de la filosofía* (1972), Madrid, 1985, 2 vol.
- *Estudios éticos*, Barcelona, 1986.
 - *Diskurs und Verantwortung*, Fráncfort, 1988
 - A. Cortina, J. De Zan y D. Michelini, *Ética comunicativa y democracia*, Crítica, Barcelona, 1991
 - *Auseinandersetzungen*, Fráncfort, 1999.
- ARATO, Andrew, «Procedural Law and Civil Society. Interpreting the Radical Democratic Paradigm», en M. Rosenfeld and A. Arato, *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*, Berkeley, California, 1998.
- ARENDT, Hannah, *La vida del Espíritu*, Madrid, 1984, p. 526.
- *¿Qué es la política?*, Barcelona, 1997.
 - *Eichmann en Jerusalén*, 2ª ed., Barcelona, 1999.
- ARNIO, A., *Lo racional como razonable*, Madrid, 1991.
- AYER, a. J., *Language, Truth an Logic*, 2ª ed., 1946, (trad. castellana: *Lenguaje, verdad y lógica*, Eudeba, Buenos Aires).
- BARBER, Benjamín, «La democracia liberal y los costos del consenso», en N. Rosenblum, *El liberalismo y la vida moral*, Buenos Aires, 1993.
- *Un lugar para todos*, Barcelona, 2000.
- BOBBIO, Norberto, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1986.
- *L'Età dei diritti*, Turín, 1990, (trad. española *El tiempo de los derechos*, Madrid, 1991.
 - *El tercero ausente*, Madrid, 1997.
- BOURDIEU, Pierre, *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*, Barcelona, 1999.
- *Poder, derecho y clases sociales*, Desclée de Bouwer, Bilbao, 2001.
- CALSAMAGLIA, A., «Ensayo sobre Dworkin», prólogo a la edición española de *Los derechos en serio*, Barcelona, 1984.

CAMPS, Victoria, «Moral pública y moral privada», en J. S. Avarezunde (ed.), *Actas del 2º Congreso Nacional de Bioética Fundamental y Clínica*, Madrid, 1999.

CANADIAN JUDICIAL COUNCIL, *Ethical Principles for Judges*, Ottawa, Ontario, 1998.

CANIVET, G., «Le droit communautaire et l'office du juge national», *Droit et Société*, 1992, nº 20-21.

CORTINA, A., *Ética aplicada y democracia radical*, Tecnos, Madrid, 1993.

- *Ética mínima*, Madrid, 1996.

- «Universalizar la aristocracia. Por una ética de las profesiones», en *Actas del 2º Congreso Nacional de Bioética Fundamental y Clínica*, Madrid, 1999.

CRUZ, Manuel, *Hacerse cargo*, Barcelona, 1999.

DAHL, Robert, *Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía vs. control*, México, 1991.

DE TOCQUEVILLE, A., *La democracia en América*, Madrid, 1968.

DE ZAN, J., «El saber y los valores en la filosofía de Max Scheler», en *Stromata*, XXXV, nº 1-2, Buenos Aires, 1979.

- «Apel y el problema de la fundamentación de la ética en la época de la ciencia» en *Stromata*, XLII, nº 1-2, Buenos Aires, 1986.

- «Pragmática del lenguaje y racionalidad comunicativa», en *Stromata*, XLVI, Buenos Aires, 1988.

- «Moralidad y eticidad, o Kant y Hegel», en *Cuadernos de ética*, nº 7, Buenos Aires, 1989.

- *Libertad, poder y discurso*, Buenos Aires, Almagesto, 1993.

- «Racionalidad científico-tecnológica y cultura», en D. Michelini y otros, *Racionalidad y cultura* (vol. col.), ICALA, Río Cuarto, 1993.

- «Ética y moral en J. Habermas», en P. Britos, J. De Zan y otros, *Éticas del siglo*, Rosario, 1994.

- «Poder, pactos políticos y procedimientos democráticos», en D. Picotti (comp.), *Pensar desde América Latina*, Catálogos, Buenos Aires, 1995.

- «Una teoría del estado de derecho», en *Cuadernos de ética*, nº 19-20, Buenos Aires, 1995.

- «Pensamiento reconstructivo y mundo simbólico», en *Tópicos* n° 4, Santa Fe, 1996.
 - «Ética, derecho y política en K.-O. Apel y J. Habermas», en D. Michelini y otros, *Eficiencia y justicia social*, Río Cuarto, 1996.
 - «El problema ético y político de la época de la ciencia y de la técnica», en C. Ruta y otros, *Saber del tiempo, tiempo del saber*, J. Baudino Ediciones, Buenos Aires, 1997.
 - «Hermenéutica y reconstrucción racional», en Mónica Cragolini y R. Maliandi (comps.), *La razón y el minotauro*, Almagesto, Buenos Aires, 1998.
 - «Wittgenstein y la ética», en *Tópicos*, n° 7, Santa Fe, 1999.
 - «Identidad y universalidad en Paul Ricoeur», en *Erasmus*, Revista Latinoamericana Interdisciplinaria del ICALA, n° 1, Río Cuarto, 1999.
 - *Panorama de la ética continental contemporánea*, Akal, Madrid, 2002
 - «Decir que no», en *Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe*, n° 10, 2002.
 - «La sociedad dividida», en *Violencia, instituciones y educación*, vol. Colectivo, editado por D. Michelini y otros, Fundación ICALA, Río Cuarto, 2002.
 - *Panorama de la ética contemporánea*, Akal, Madrid, 2003
 - «La exclusión del otro», en *Erasmus*, V, n° 2, Río Cuarto, 2003.
 - «Filosofía y política en Hannah Arendt», en *Cuadernos del Sur*, Revista de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2003
 - *La filosofía práctica de Hegel*, ICALA, Río Cuarto, 2003.
 - «La filosofía de la liberación de los '70 y la Argentina del siglo XXI», en *Erasmus*, V, n° 1-2, 2004.
 - «E. Tugendhat: Filosofía analítica y fundamentación de la ética normativa», *Teoría*, Tucumán, n° extraordinario en homenaje al Prof. Dr. Roberto Rojo, 2004.
- DELMAS MARTY, M., *Pour un droit commun*, Ed. Du Seuil, París, 1994.

DERRIDA, J., *Fuerza de ley. El «fundamento mítico de la autoridad»*, Tecnos, Madrid, 1997.

DWORKIN, Ronald, *Los derechos en serio*, Barcelona, 1984.

- Law's Empire, Cambridge, Massachussets, 1986.
- *Ética privada e igualitarismo político*, (1990), Barcelona, 1993.
- *La comunidad liberal*, Bogotá, 1996.

ELLSCHIED, G., W. HASSEMER (eds.), *Interessen jurisprudence*, Darmstadt, 1974.

FALK, Richard, «Una revisión del cosmopolitismo» en M. Nussbaum, 1999.

FARELL, M. D., «La ética de la función judicial», en J. Malem, y otros, *La función judicial. Ética y democracia*, Gedisa, Barcelona, 2003.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. L. y A. HORTAL ALONSO (comp.), *Ética de las profesiones jurídicas*, Comillas, 2001.

FISS, O., «Objectivity and Interpretation», en *Stanford Law Review*, 34, 1982.

FORNARI, A., en J. DE ZAN y otros, «Los fundamentos de la ética en la época contemporánea. Problemas y propuestas», *Tópicos. Revista de filosofía de Santa Fe*, n° 3, 1995.

FORST, R., *Kontexte der Gerechtigkeit*, 1994.

GADAMER, Hans-Georg, «Hermeneutik als praktische philosophie», en el libro del mismo: *Vernunft im Zeitalter der Wissenschaften*, Fráncfort, 1976, p. 78 ss.

- GADAMER, H.-G., *Verdad y método I*, Salamanca, 1993.
- GADAMER, H.-G., *Verdad y método II*, Salamanca, 1998.

GARAPON, A., *Le Gardien des Promesses. Justice et Démocratie*, (París, 1996), (trad. esp. *Juez y Democracia*, Madrid, 1997).

GARCÍA PASCUAL, G., *Legitimidad democrática y poder judicial*, Valencia, 1997.

GARGARELLA, R., *La Justicia contra el gobierno*, Ariel, Barcelona, 1996.

- *Crítica de la Constitución. Sus zonas oscuras*, Buenos Aires, 2004.

GAUCHET, M., «L'expérience totalitaire et la pensée du politique», en *Esprit*, n° 7-8, 1976.

- GRAY, John, *Las dos caras del liberalismo*, Barcelona, 1993.
- *Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia liberal*, Paidós, Barcelona, 2000.
- GUARIGLIA, O., *Moralidad, Ética universal y sujeto moral*, Buenos Aires, FCE, 1996.
- GUARIGLIA, O., *Una ética para el siglo XXI. Ética y derechos humanos en un tiempo posmetafísico*, FCE, Buenos Aires, 2002.
- GUÉHENNO, Jean-Marie, *El fin de la democracia. La crisis política y las nuevas reglas de juego*, Barcelona, 1995.
- GÜNTHER, Klaus, *Der Sinn für Angemessenheit. Anwendungsdiskurse in Moral und Recht*, Fráncfort, 1988.
- HABERMAS, Jürgen, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Fráncfort, 1981, 2 tomos, (trad. esp.: *Teoría de la acción comunicativa*, Madrid, 1987).
- *Erläuterungen zur Diskursethik*, Fráncfort, 1991, (trad. española: *Aclaraciones a la ética del discurso*, Madrid, 2000).
 - *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp. Fráncfort, 1992, (traducción española: *Facticidad y Validez. Contribuciones para una teoría discursiva del derecho y del estado de derecho democrático*, Madrid, 1998).
 - «El Estado-nación europeo y las presiones de la globalización», en *New Left Review*, n° 1, Barcelona, 2000.
 - *Die Einbeziehung des Anderen*, Fráncfort, 1996, (trad. La inclusión del otro, Madrid, 1999).
- HAMPSHIRE, Stuart, *Moral pública y privada*, (1978), México, 1983.
- HASSEMER, Winfried, «Juristische Hermeneutik», en *Archiv für Rechts- und SozialPhilosophie*, n° 72, LXXII/Heft 2, Stuttgart, 1986.
- HEGEL, G.W.F., *Filosofía del derecho*.
- HELD, David, *Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Democracy*. Polity Press, Londres, 1995.
- «Violencia y justicia en una era mundial», diario *El País*, Madrid, 19 de septiembre de 2001.
 - «Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty», en *Legal Theory*, I, 2002.

- A. MCGREW, *Governing globalization. Power, authority and global governance*, Polity Press, Cambridge, 2002.
- HIERRO PESCADOR, J., «Ética», en *Diccionario de filosofía contemporánea*, Salamanca, 1979.
- HOBBS, TH., *De Cive*, (trad. esp. Sobre el ciudadano, Trotta, 2002).
- HÖFFE, Otfried, *Derecho intercultural*, Barcelona, 1999.
- «¿Hay un derecho penal intercultural? Ensayo filosófico», en *Erasmus*, n° 1, Río Cuarto, 1999.
- *Demokratie im Zeitalter der Globalisierung*, Múnich, 1999.
- HONNETH, Axel, *La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales*, Crítica, Barcelona, 1997.
- HUDSON, W. D., *La filosofía moral contemporánea*, Madrid, 1974.
- KANT, I., *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (Ak. Ausg., IV, 415), ed. española bilingüe, Ariel, Barcelona, 1996.
- KYMLICKA, Will, «La tradición del contrato social», en P. Singer, *Companion to Ethics*, 1991, (trad. esp. Compendio de ética, Madrid, 2000).
- LARENZ, K., *Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica*, Civitas, Madrid, 1985.
- LENOBLE, Jacques, «Law and Undecidibility», M. Rosenfeld and A. Arato, en *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*, Berkeley, California, 1998.
- LYOTARD, J.-Fr., *Tombeau de l'intellectuel*, París, 1984.
- MACINTYRE, A., *After Virtue*, New York, 1984; *Tras la virtud*, Crítica, Barcelona, 1987.
- MACKIE, John L., *Ética. La invención de lo bueno y de lo malo*, (1977), Barcelona, 2000.
- MALAMUD GOTTI, J., *Los dilemas morales de la Justicia internacional. El caso Pinochet*, Ciepp/Miño y Dávila, Buenos Aires, noviembre de 2003.
- MALIANDI, Ricardo, *Ética, conceptos y problemas*, 3ª ed., Biblos, Buenos Aires, 2004.
- MAUS, I., *Zur Aufklärung der Demokratietheorie*, Fráncfort, 1992.
- MICHELMANN, F., «Justificatio and the Justificabilty of Law», en *Nomos*, XVIII, 1986.

MOUFFE, CH., «Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal», en *Tópicos. Revista de filosofía de Santa Fe*, n° 10, 2002.

NAGEL, Thomas, «Los grandes crímenes modernos son crímenes públicos», en Stuart Hampshire, 1983.

- «La crueldad en la vida pública», en Stuart Hampshire, 1983.

NEGRI, T., M. HARDT, *Multitud, guerra y democracia en la era del imperio*, Sudamericana, Buenos Aires, 2004.

NINO, C., *Ética y derechos humanos*, Buenos Aires, Paidós, 1984.

ORTEGA Y Gasset, J., *La rebelión de las masas* (1926), Buenos Aires, 1949.

PELLEGRINO, E. D., D. C. THOMASMA, *The virtues in medical practice*, New York/ Oxford, 1993.

PERELMANN, Ch., L.OLBRECHTS-TYTECA, *La nouvelle rethorique* (1958), 2a ed., Bruselas, 1970.

PETERS, B., *Rationalität, Recht und Gesellschaft*, Fráncfort, 1991

PIAGET, J., *El criterio moral en el niño*, Martínez Roca, Barcelona, 1984.

PIEGLER, JOSEF , «Der Richter im Rechtsstaat», *Österr Juristenzeitung*, 1965.

POPPER, Karl, *Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico*, Barcelona, 1983.

RADBRUCH, *Die Natur der Sache als juristische Denkform*, 1960.

RAWLS, John, *Una teoría de la justicia* (1971), México, 1979.

- *Political liberalism*, New York, 1993, (trad. *El liberalismo político*, Crítica, Barcelona, 1996.

El derecho de gentes (1999), Barcelona, 2001.

RAYNAUD, PH. y ST. RIALS (ed.), *Diccionario de filosofía política*, Madrid, 2001.

RICOEUR, P., *Soi-même comme un autre*, 1990, (edic. castellana: *Sí mismo como otro*, México, 1996).

RIUTORT SERRA, Bernat, *Razón política, globalización y modernidad compleja*, El Viejo Topo, España, 2001.

- (ed.), *Conflictos bélicos y nuevo orden mundial*, Barcelona, 2003.

RORTY, Richard, *Contingencia, ironía y solidaridad*, Paidós, Barcelona, 1991.

SCHAMBECK, Herber, «Richteramt und Ethic» en *Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte*, Band 15, Duncker and Humboldt, Berlin.

SCHELER, Max, *El resentimiento en la moral*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, México, 1944.

- *El puesto del hombre en el cosmos*, Buenos Aires, 1964.

SCHMITT, Carl, *Sobre el parlamentarismo*, Tecnos, 1990.

SHIENTAG, B. L., «The Virtue of Impartiality», en G. R. Winters (ed.), *Handbook for Judges*, American Judicature Society, 1975.

SINGER, Peter, *One World*, (2002), (trad. *Un solo mundo. La ética de la globalización*, Paidós, Barcelona, 2003).

SOUZA Santos, B., *La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*, Bogotá, 2002.

SUMNERS, R. S., *Instrumentalism and American Legal Theory*, Ithaca, 1982.

TARELLO, G., *Cultura giuridica e política del diritto*, Bolonia, Il Mulino, 1988.

TAYLOR, Charles, «Propósitos cruzados: el debate liberal-comunitario», en R. Rosenblum, *El liberalismo y la vida moral*, Buenos Aires, 1993.

THOMAS, James Burrows, *Judicial Ethics in Australia*, The Law Book Company, Sydney, 1988.

THOMPSON, Dennis, *La ética política y el ejercicio de cargos públicos*, Barcelona, 1999.

TORBISCO CASAL, N., «Sobre la relevancia de la justicia internacional», en Malamud Jaime, *Los dilemas morales de la justicia internacional. El caso Pinochet*, CIEPP/Miño y Dávila, 2003.

TUGENDHAT, Ernst, *Lecciones de Ética*, Barcelona, 1997.

TULMIN, S., *Uses of Argument*, Cambridge, 1958.

VALCARCE, Amelia, *Ética para un mundo global*, Madrid, 2002.

VATTIMO, G., J. DERRIDA, *Diritto, giustizia e interpretatione. Anuario filosófico europeo*, Roma-Bari, Laterza, 1998.

VIGO, R. L., *Perspectivas iusfilosóficas contemporáneas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991.

VIRNO, Paolo, *Gramática de la multitud*, Colihue, Buenos Aires, 2003.

WALZER, Michel, «Political action: the problem of dirty hands», en *Philosophy and Public Affairs*, 2, n° 2, 1973.

- *Thick and Thin. Moral Arguments at home and Abroad*, New York, 1994, (trad. esp. *Moralidad en el ámbito local e internacional*, (1994), Madrid, 1996.
- *Jus and Unjust Wars*, Harmondsworth, Penguin, 1980, (trad. esp.: Barcelona, Paidós, 2001).

WAYNE MACKAY, A., «Judicial Ethics: Exploring Misconduct and Accountability for Judges», Dalhousie University, 1995, Discussion Paper for Commonwealth Chief Justices Roundtable Meeting, <<http://is.dal.ca/~cjei/mackay.html>>.

WEBER, M., *Politik als Beruf. Wissenschaft als Beruf* (trad. esp. *La política como vocación*, Madrid, 1975).

- *La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie)*, I, pp. 1-202), Premia, México, 1981.

WINCH, P., *The idea of a Social Science*, London, 1958.

WINGERT, L., *Gemeinsinn und Moral*, 1993.

ZOLO, Danilo, *Cosmópolis (Perspectiva y riesgos de un gobierno mundial)*, Paidós, Barcelona, 2000.

DERECHO Y MORAL

Siguiendo una vieja tradición académica*, recojo el símbolo del cargo de manos de mi estimado predecesor, y suplico, ante todo, se rae permita expresarle mi gratitud por las hermosas y cordiales palabras que acaba de pronunciar.

Le doy también las gracias a nombre de la Universidad, del Senado Académico y de las Facultades, por todo lo que ha hecho por la Universidad durante el año rectoral que acaba de transcurrir, por sus múltiples y valiosos esfuerzos siempre coronados de éxito y por el enorme cúmulo de talento, trabajo y dedicación que puso al servicio de su cargo. La Universidad no olvidará todo eso.

De acuerdo con una hermosa costumbre académica, pido, además, se me permita contribuir a la fiesta de hoy con algunas meditaciones acerca del campo de mis investigaciones. Versarán sobre un tema que es para todos nosotros de la mayor importancia, tanto en lo que se refiere a los fundamentos de nuestra concepción del mundo, cuanto en lo que concierne a las decisiones prácticas inmediatas que a diario tomamos en la vida privada, en el derecho y en la política. Se trata del problema del derecho y la moral.

Claro es que en el breve lapso en que puedo ocupar la paciencia de ustedes, sólo me será posible trazar escuetos contornos, semejantes a las pocas líneas con que un pintor bosqueja el cuadro antes de realizarlo. Yo debo también, como el pintor, reservar la ejecución a trabajos posteriores.

Nuestro punto de partida lo constituye el juicio de valor, el juicio sobre el bien y el mal y la vivencia correspondiente del deber, de la obligación, de la orden, del mandato, del imperativo, de la norma, o, en otras palabras, la pregunta ¿qué debo hacer? o ¿qué es bueno?

* Discurso rectoral pronunciado por el doctor Rudolf Laun el día 10 de noviembre de 1984, al tomar posesión de la rectoría de la Universidad de Hamburgo. (Nota del Traductor.)

Ya Shaftesbury reconoció que la respuesta a esa pregunta no puede derivarse de la amenaza divina de una recompensa o castigo, ni tampoco de leyes naturales, físicas o fisiológicas, sino que el juicio de valor es de especie propia. Pero Shaftesbury no pensó hasta el final este pensamiento.

Como es sabido, fue Kant el primero en fundar una nueva ética, independiente de los dogmas religiosos y las leyes naturales, al concebir la diferencia entre el *acontecer* y el *deber* como una oposición de categorías irreductibles de nuestro conocimiento.

Esta oposición entre el ser y el deber es fundamental para nuestro pensamiento. Domina incluso nuestra clasificación suprema de las ciencias. En efecto, distinguimos las ciencias causales de las normativas, o imperativistas. Las primeras indagan lo que es; las segundas, lo que debe ser.

La ética y la ciencia del derecho pertenecen a ambos campos. De una parte, estudian las costumbres e instituciones jurídicas existentes de manera causal, descriptiva y explicativa, histórica, psicológica y sociológica. Pero, de otra, preguntan ¿qué debo hacer?..., ¿qué estoy obligado a hacer? Hablamos entonces de una ética y una ciencia jurídica imperativista o normativa. Los juristas llaman, de preferencia, dogmática a la consideración imperativista del derecho. Procede también normativa o dogmáticamente la práctica de los tribunales, de las autoridades y abogados y de toda la literatura jurídica enfocada hacia una aplicación práctica. Porque en todos estos casos no se quiere describir o explicar causalmente, sino contestar la pregunta ¿qué debe ser?, ¿qué es justo o injusto?

¿Cómo se puede responder a la pregunta *qué debo hacer*?

Nos encontramos aquí frente a una grave dificultad. Del ser no es posible derivar ningún deber. De que el mundo causal transcurra de tal o cual manera, no se sigue todavía que yo o alguien deba hacer algo. De que alguien ordene algo —por ejemplo—, o que lo obtenga por la fuerza, no se infiere que otro esté obligado a obedecer.

En el campo de la moral, Kant y todos los partidarios de la ética imperativista eludieron la dificultad. Kant enseñó que la ley moral es autónoma, que el hombre «sólo está sometido a una legislación propia y sin embargo general». Lo cual significa que quien

cumple un deber moral obedece a una ley que él mismo se ha dado, convencido de su universal validez.

Pero ¿qué sucede con el derecho?

Todos los juristas, teóricos y prácticos, han estado acordes desde siempre en que éste es *heterónomo*, es decir, que en él no nos liga la voluntad propia, sino una voluntad extraña, la del llamado legislador.

Pero al mismo tiempo, todos los que han comprendido la oposición de las categorías epistemológicas del acontecer y el deber, llegan con necesidad ineludible a la conclusión de que el derecho pertenece al mundo normativo.

El derecho vale, por tanto, como un *deber heterónomo*, esto es, como un sistema de mandatos, imperativos y deberes, cuyo contenido nos es impuesto por una voluntad extraña, precisamente la del legislador, ya sea que nos obligue inmediatamente —como acepta sin críticas la mayoría—, o sólo nos ligue mediatamente, derivando su autoridad de la ley moral —como en Kant—, o sometiéndonos nosotros al derecho por virtud de una aceptación general o —según la frase de Radbruch— «aceptándolo en blanco».

A esta concepción de la ciencia y la práctica del derecho como deber heterónomo me opongo yo, sin embargo. Si no nos conformamos con la descripción y explicación causal, sino que queremos contestar a la pregunta ¿qué debo hacer?, pregunta que forzosamente tenemos que planteamos, debemos entonces afirmar que los mandatos jurídicos son objeto de la auto-legislación o —en otras palabras— *que son autónomos*.

Los mandatos del derecho son autónomos, pues quien obedece un deber jurídico, no una necesidad o una coacción, sigue tan sólo una ley que él mismo se ha dado para cada caso de aplicación concreta.

Para poder fundar y desarrollar mi tesis y derivar de ella conclusiones ulteriores, séame permitido retroceder hasta su supuesto último y más general: la categoría epistemológica del deber, del mandato, del imperativo.

También aquí encontraremos en Kant las bases de nuestro pensamiento, aunque en una forma que en parte debo criticar.

Como es sabido, el filósofo de Koenigsberg enseña que todos los imperativos son hipotéticos o categóricos. Los hipotéticos ordenan una acción como medio para un fin; los categóricos, en cambio —sin referencia a ningún fin— la ordenan como buena en sí. Categórica es, por tanto, únicamente la ley moral que nos obliga inmediatamente como un fin supremo, como un fin en sí. Todos los demás imperativos son hipotéticos; son reglas de la habilidad y de la inteligencia. Que el fin al que sirvan como medios sea moral, no interesa. Así —por ejemplo— observan el médico y el envenenador las mismas prescripciones: uno para aliviar al paciente, el otro para matar a su víctima.

Imperativos hipotéticos son también —según Kant— las leyes jurídicas que, en oposición a la ley moral autónoma, se conciben como leyes heterónomas. La ley moral es en el sentido kantiano un deber categórico; las leyes jurídicas, en cambio, son deberes hipotéticos.

Se afirma aquí, por tanto, una oposición entre las formas epistemológicas de lo categórico y lo hipotético. Tal vez fuera preferible hablar de lo incondicionado y lo condicionado, porque la expresión «categórico» se necesita —como he procurado demostrarlo en otro lugar (*Archivo de derecho público*, tomo XXXIV)— para designar el opuesto categórico de «disyuntivo».

Ahora bien, me veo obligado a sostener que el más grande de todos los pensadores, en su doctrina del imperativo, no ha distinguido con la necesaria precisión *el imperativo como categoría epistemológica —el deber en oposición al acontecer— del imperativo como simple medio lingüístico de expresión*.

Es cierto que la gramática conoce frases imperativas condicionadas e incondicionadas; pero eso nada tiene que ver con nuestro problema, porque lingüísticamente se pueden formular incondicionadamente las frases más diversas, no sólo la ley moral.

Pero si invocamos, no la forma lingüística, sino el contenido lógico, habrá que concluir de la siguiente manera: la relación entre medio y fin es causal. Los imperativos hipotéticos de Kant expresan la relación de medio a fin. En consecuencia, son expresiones de una relación causal. Del acontecer causal, empero, no es posible derivar ningún deber. Por tanto, según la misma distinción kantiana del deber y del acontecer, no significan ningún deber, ningún imperativo, sino un acontecer.

El mismo Kant comprendió que los imperativos hipotéticos se encontraban frente a los categóricos en una oposición distinta de la de lo condicionado frente a lo incondicionado. A ello alude repetidas veces, como cuando dice que los imperativos de la inteligencia, «hablando con precisión, no ordenan», sino que más bien deben considerarse como «consejos (*consilia*) o preceptos (*praecepta*) de la razón»; pero, sin embargo, él los trató como imperativos, como deberes. En especial unió los imperativos jurídicos, aunque —en su opinión— son tan sólo hipotéticos, con los de la moral, bajo el concepto de «leyes de la libertad», y juntos los opuso —como leyes del deber o «morales»— a las de la naturaleza —o leyes de la necesidad. Pero como expresión de relaciones causales, los llamados imperativos hipotéticos no son la manifestación de un deber, por tanto, tampoco de un deber condicionado, sino declaraciones sobre una necesidad condicionada.

Esto lo demuestra el propio ejemplo de Kant. Las reglas sobre las mezclas de medicinas y venenos, no me dicen que yo deba emplear una determinada, sino que *tengo* que aplicarla como consecuencia de una necesidad causal, si quiero curar una enfermedad o matar a un hombre. Esto no es un deber sujeto a condición, sino una necesidad condicionada.

Otro ejemplo: las reglas de la gramática inglesa no me dicen que deba yo hablar en determinada forma, sino que —por virtud de una necesidad causal— *tengo* que hacerlo así, si quiero hablar y ser entendido como si fuera un inglés.

Pero si ello me es indiferente, como en el caso de que no desee aprender inglés, desaparece la condición de la necesidad y las reglas de la gramática no me importan lo más mínimo. Esas reglas no contienen un deber, una obligación.

Sin embargo, también aquella conducta que es objeto de la expresión del llamado imperativo hipotético puede convertirse en contenido de un deber, como cualquiera otra conducta causal. Supongamos —por ejemplo— que, por su profesión, el médico está obligado moral o jurídicamente a curar a un enfermo según su leal saber y entender, o que alguien está obligado también profesionalmente a aprender inglés con todo empeño. Entonces las reglas técnicas, los «imperativos hipotéticos» de la terapia o de la gramática inglesa se

convierten mediatamente en objeto de un deber. Pero, aun entonces, debe separarse la necesidad causalmente condicionada, del deber. Las reglas técnicas de la terapia o de la gramática inglesa, no me obligan inmediatamente como tales, sino que mi obligación tiene un fundamento especial, jurídico o moral, situado más allá de dichas reglas. Al desaparecer éste, resulta evidente que aquellas reglas no tienen por objeto un deber, una obligación.

Hemos llegado, pues, a esta conclusión: *un imperativo, en sentido lingüístico, es o heterónomo –en cuyo caso no puede implicar un deber– o implica un deber –pero entonces no puede ser heterónomo*. Si tratamos de traducir este pensamiento del lenguaje de los filósofos al español, podemos decir lo siguiente: *una frase que me ordena algo es o expresión de una voluntad ajena –en cuyo caso no me puede obligar– o me obliga – pero entonces no puede ser expresión de una voluntad extraña*.

Ahora bien, como en el derecho buscamos obligaciones y deberes, de aquí se sigue que los mandatos jurídicos no pueden ser expresión de una voluntad extraña, sino únicamente de la propia, o, en otras palabras, que *esos mandatos son autónomos*.

Pero con ello no queda resuelto el problema. Existen evidentemente muchos mandatos que unos dan y otros obedecen; esto es, que se nos presentan como heterónomos, como, por ejemplo, los del llamado «derecho positivo».

Según la opinión dominante, las fuentes de tal derecho son:

1º Las costumbres, es decir, el llamado derecho consuetudinario, o no-escrito.

2º Las leyes y convenios estatales, el derecho escrito o legislado; y

3º Además, según la opinión más difundida, las órdenes de un poderoso o vencedor ante las que se doblegan los más débiles o los vencidos, sin que exista una costumbre ni se observen las formas determinadas de la legislación o de los convenios, como en el caso de la revolución y del golpe de Estado.

En todos estos casos una voluntad extraña, la del legislador, la de las autoridades o demás personas detentadoras del poder, quiere someter a los demás.

Pero de lo que hagan los detentadores del poder, de que dicten, promulguen y publiquen leyes y las impongan por la fuerza, no se

infiere que alguien deba obedecer; de los discursos, firmas, papeles impresos y bayonetas no se sigue ningún deber. El llamado derecho positivo no tiene, por ende, como contenido, ningún deber, sino únicamente una necesidad condicionada.

El hecho de que la obediencia o desobediencia traigan consigo consecuencias jurídicas, implica una necesidad.

Dichas consecuencias jurídicas consisten primeramente, tratándose de los ordenamientos jurídicos dotados de fundamentos religiosos, en recompensas y castigos en el más allá, en los que creen los que están sometidos al derecho, y por virtud de los cuales obedecen los mandatos de las autoridades terrenas. Si prescindimos de todo postulado metafísico y permanecemos en la esfera del llamado mundo de la experiencia, tendremos que reconocer que esas consecuencias jurídicas son recompensas, castigos y coacción. Pues la recompensa desemboca en último término en una coacción que se ejerce sobre el órgano que ha de otorgarla.

La consecuencia jurídica es, por consiguiente, la aplicación de la fuerza por parte del más poderoso contra el más débil. En donde resalta esto con más claridad es en las relaciones interestatales, en el derecho internacional. Pero vale también para los demás sectores. El poder coactivo del Estado no es otra cosa que el poder de aquel que en un cierto territorio es el más fuerte y el mejor organizado. ^x

El llamado derecho positivo – en consecuencia – es un conjunto de declaraciones sobre la aplicación condicionada del poder del más fuerte. Es poder, pura y simplemente. No contiene ningún deber, ninguna obligación.

Pero esta consideración causal no es por sí sola suficiente, porque no nos permite emitir un juicio de valor. Por ello nos hace imposible obtener una imagen cierta del universo, una concepción del mundo, que naturalmente debe también responder a la pregunta ¿qué *debo* hacer? Tampoco satisface a la práctica la consideración puramente causal, porque ella tiene asimismo que preguntar constantemente ¿qué debe suceder? Si prescindiéramos de un juicio de valor, tendríamos incluso que equiparar – según el llamado derecho positivo – al ladrón a quien no se puede probar su delito, con el hombre honrado que no aprovecha, para robar, una oportunidad segura y sin peligro. Sin un juicio de valor únicamente habría una

diferencia técnica y cuantitativa entre el Estado y una banda de ladrones, incluso según el llamado derecho positivo, que es, en el caso, el derecho internacional. Para esta concepción sólo existe la fuerza. El derecho se reduce entonces a la voluntad del más fuerte o del vencedor. Entre los hombres vale el mismo «derecho» que entre los animales: el más fuerte devora a su gusto al más débil, mientras no se lo impida alguien más fuerte todavía, y con ello no viola ningún «deber» ni comete tampoco ninguna «injusticia». La palabra «derecho» resulta entonces superflua. No hablamos —por ejemplo— del «derecho» del lobo de destrozar a la oveja.

Por tal razón sería más exacto no hablar nunca del «derecho del más fuerte» o del vencedor, sino siempre del «poder del más fuerte» o del vencedor, y —en consecuencia— preferible sería también no hablar nunca del «derecho positivo», sino siempre del «poder positivo», en cuyo caso podría perfectamente suprimirse la palabra «positivo».

Pero desde antaño es costumbre aplicar el título honorífico de «derecho» a los preceptos heterónomos, porque en todos los tiempos los detentadores del poder han sabido presentar su voluntad como si fuera el «derecho» mismo. En la actualidad no podemos todavía suprimir ese uso del lenguaje, pero no por ello debemos dejarnos engañar por la palabra. Tenemos que estar seguros de que *del poder no es posible derivar ningún deber, ni aun en el caso de que se llame «derecho» a la fuerza*.

Por esta razón deberíamos —al menos en la ciencia— hablar siempre del «derecho positivo» o introducir designaciones como —por ejemplo— «derecho heterónimo» o «derecho de la fuerza», para evitar, en estos giros, toda apariencias de consagración moral.

Pero un número de hombres que en los pueblos civilizados crece paulatinamente, conforme aumenta la cultura, se opone a considerar el derecho sólo causalmente, sólo como poder. Claro es que la mayoría no piensa teóricamente sobre estas cosas, pero obra de acuerdo con ellas. Los más no robamos ni siquiera en el caso de que pudiéramos hacerlo con toda seguridad y sin ningún peligro. También establecemos entre el Estado y la banda de ladrones una diferencia no puramente técnica y cuantitativa, sino axiológica. Por ello fueron a la guerra cientos de miles, impulsados por el sentimiento

del deber, y sufrieron voluntariamente en el campo de batalla, en nombre de ese sentimiento, las más duras penalidades. Más aún, muchos prefirieron la muerte al incumplimiento del deber, aun en aquellos casos en que habrían podido violarlo impunemente. Aunque los ejemplos de semejantes heroísmos representan sólo una minoría, en un inmenso número de casos puede empero observarse un sentimiento del deber menos elevado, menos heroico.

El deber —por tanto— existe. Es objeto de una vivencia. En medio de las consideraciones de la propia conservación y del egoísmo que llenan la mayor parte de nuestra existencia, vivimos también esa pregunta que nos hacemos a nosotros mismos: ¿qué debo hacer?, ¿cuál es mi deber? En el lenguaje usual se llama a esto la voz de la conciencia o del sentimiento jurídico.

A los hombres incapaces de tales inquietudes los llamamos sin conciencia. Por numerosos que sean, no podemos construir, sobre ellos únicamente, el derecho y el Estado, por lo menos en la etapa actual de la evolución, en que el miedo a los castigos infernales ya no lo domina todo. Porque si todos obedecieran sólo bajo la presión de la fuerza, habría que colocar detrás de cada gendarme a un segundo para empujar al primero, y detrás del segundo a un tercero, y así sucesivamente.

El derecho y el Estado descansan, por tanto, indiscutiblemente, sobre el hecho de que una gran parte de los hombres viven realmente el deber, la obligación.

Ahora bien, cómo contestan esos hombres a la pregunta ¿qué debo hacer?, ¿cuál es mi deber?

El conocimiento del mundo causal no puede brindarles la respuesta, porque del acontecer no se sigue deber ninguno. Ciertamente es que muchos hablan del deber y piensan únicamente en el ejecutor, en la prisión o en el infierno, esto es, en una necesidad condicionada, pero no en el deber mismo. Mas de lo expuesto se deduce que obrar por miedo es algo esencialmente distinto de obrar por deber, por presión interna del sentimiento jurídico o de la conciencia. La conducta externa puede, es cierto, ser presionada por amenazas o por la fuerza, pero la aprobación de la conciencia o del sentimiento jurídico, incluso del último y más hábil, no puede ser arrancado por ningún poder terreno.

Del mundo causal en que actúan los legisladores, verdugos y carceleros no puede —por tanto— obtenerse el contenido de lo que debo hacer. *Sólo podemos damos cuenta de aquello que debemos hacer, del contenido de nuestro deber, por la propia e inmediata vivencia.* Esta vivencia nadie puede conocerla si no es por experiencia propia. A quien no sea capaz de vivencia semejante, a quien no haya escuchado la voz de la conciencia ni experimentado la inquietud del sentimiento jurídico, no es posible describirla ni, menos aún, enseñarla.

Sea ello como fuere, precisa puntualizar que la vivencia del deber, de la obligación, no es tan sólo la de un interés cualquiera, la de una inclinación egoísta. De otro modo, todo lo que alguien quisiera sería al mismo tiempo lo que debe, y el crimen resultaría tan obligatorio como la acción más altruista. La vivencia del deber tiene más bien que abarcar la convicción, aunque inconsciente, de que en la misma situación todo hombre estaría obligado a obrar del mismo modo, lo que implica —por ende— un juicio de valor no sólo sobre la propia conducta, sino también sobre la humana en general.

Por ello no podemos, refiriéndonos a animales, hablar de un deber moral o jurídico, de una obligación, y, tratándose de hombres y pueblos primitivos, sólo podemos hacerlo en relación con cosas primitivas. Pero también en los peldaños más elevados es muy distinto, individualmente, el círculo dentro del cual se vive un deber. Evidentemente está determinado por muchos factores causales; sobre todo por la educación política del individuo y del pueblo.

Pero las vivencias del deber no pueden ser explicadas de un modo exhaustivo en su contenido, en su peculiaridad de criterio axiológico supremo y soberano, por factores tomados del mundo causal, *sino que revelan, en cada momento en que se realizan, fragmentos del carácter del individuo, del pueblo y de la humanidad, comprensibles tan sólo metafísicamente.*

La vivencia del deber es una vivencia primaria en su contenido concreto y, en consecuencia, científicamente irreductible e inexplicable.

Estas vivencias primarias son incondicionadas, como las del acontecer. Yo no puedo ver lo blanco condicionadamente, sino que lo veo o no lo veo. Del mismo modo tampoco puedo tener ninguna vivencia condicionada del «tú debes» en relación con un hecho con-

creto, esto es, que me he dado de manera incondicionada. O la tengo o no la tengo.

Por tanto, mientras las reglas heterónomas son todas condicionadas, el deber autónomo es incondicionado. Sólo tendré que abstenerme del robo en el caso de que quiera evitar la cárcel y el infierno. A quien no intimiden éstos, ningún obstáculo se opone en el mundo causal a ese delito. En cambio, si tengo la vivencia «no debes robar», esa vivencia es incondicionada en cada caso concreto y en relación con cada hecho.

Tampoco aquí debemos dejamos engañar por la forma lingüística que, tratándose de frase lógicamente incondicionada, suele reproducir los hechos en forma condicional.

La vivencia del deber no sólo es dada incondicionalmente, sino también ineludiblemente, con absoluta necesidad. Ciertamente es que puedo obrar contra la llamada voz de mi conciencia o contra el sentimiento jurídico, pero no negarla cuando está presente. Menos aún puedo suplirla cuando está ausente.

La vivencia del deber ser es —desde luego— algo enteramente subjetivo. Pero de la conformidad de una pluralidad de personas resulta una objetividad empírica, aunque sólo relativa, del derecho autónomo. Porque para cada uno el sentimiento jurídico de los demás queda fuera de su propia subjetividad y es algo objetivamente dado.

La conformidad puede ser simultánea y —por ejemplo— «exteriorizarse», bajo determinadas circunstancias, en las elecciones y plebiscitos que se realizan sin coacción ni engaño o en revoluciones u otros movimientos populares espontáneos. Pero la concordancia, incluso de muchos, puede existir aunque no se manifieste de manera tan clara. El artículo tal o cual del *Código civil* puede, independientemente de la coacción con que sea impuesto en el mundo causal, representar una magnitud de objetividad empírica relativa, en el caso de que miles de jueces y abogados consideren dicha disposición en un sentido determinado como derecho y semejante práctica se apoye en la confianza general de millones de personas, aunque éstas no conozcan siquiera el artículo o incluso algunas de ellas, en casos aislados, se rebelen contra él movidas por un sentimiento jurídico divergente.

Pero también debe tenerse en cuenta una conformidad o continuidad en sucesión cronológica, como en muchos casos de formación de derecho consuetudinario y en otras evoluciones que nos ofrece la historia del derecho. Tales concordancias y coincidencias pueden rastrearse a través de generaciones, quizás a lo largo de la historia de todo un pueblo o, incluso, de toda la humanidad. Porque aquello que cambia *indudablemente* de pueblo a pueblo y de época a época, son tan sólo los *hechos* a los que se refieren los juicios de valor. Pero es un problema muy distinto saber si también estos juicios y el carácter humano están por completo históricamente condicionados, o es posible afirmar algo que exista con independencia del mundo causal dado; en otras palabras, si toda la historia está dominada exclusivamente por leyes causales, por leyes naturales del acontecer social o propias del carácter humano, comprensibles tan sólo metafísicamente. Abordar hoy este problema nos llevaría demasiado lejos. Pero de lo dicho se sigue ya que debemos decidimos por la segunda parte de la alternativa. *Pero entonces debe permitírse nos preguntar por un derecho distinto de la subjetividad del individuo y, en este sentido, objetivamente autónomo, hacia el cual se dirige lentamente la humanidad, partiendo primitivamente de la fuerza bruta animal, a través de toda su historia, hasta realizarlo plenamente.* Mas este derecho nunca nos es dado de otro modo que en una suma de vivencias individuales, subjetivas y autónomas del deber, de la obligación.

¿Cómo se comporta, ahora, el derecho autónomo respecto del llamado positivo?

En las vivencias del deber agregamos a los procesos del mundo causal algo nuevo, algo propio, la ley de nuestro carácter. Por la adición de esta vivencia en el caso concreto, se convierten los preceptos heterónomos y condicionados del llamado derecho positivo, que en sí sólo implican una necesidad, una fuerza condicionada, *en deberes incondicionados y autónomos para dicho caso individual de aplicación; se convierten en derecho verdadero.* En otras palabras: aquello que decretó la fuerza y que en sí no obliga a nadie, *se convierte para mí en el caso individual de aplicación, en derecho obligatorio, por virtud de la aprobación de mi conciencia o de mi sentimiento jurídico.* Por esto podríamos llamar al derecho autónomo, al derecho verdadero, «derecho del sentimiento», en oposición al heterónimo, «positivo», aparente, «derecho de la fuerza».

Por tanto, no puede hablarse de un reconocimiento del orden jurídico como totalidad, de una «aceptación en blanco». De otro modo, sólo nos quedaría la alternativa entre una obediencia muerta, ciega, sin crítica, frente a todo aquello que nos impongan los órganos de quien detenta el poder, y la negación completa de todo derecho, la anarquía. Pero nadie piensa de esta manera, sino que, por lo contrario, todos distinguimos entre aquellos preceptos positivos que consideramos como «derecho» (*Recht*) y aquellos otros que consideramos como «entuerto» (*Unrecht*).

Sin embargo, aquel cuya mentalidad ha sido en cierto modo deformada por un estudio positivista del derecho, no se atreve ya a afirmar que una ley o un convenio estatal le causen agravio. *Pero todos los demás piensan, hablan y obran de ese modo.*

Quien reconozca —por ejemplo— la institución de la propiedad privada, por regla general no tocará voluntariamente la propiedad ajena, aun en el caso de que pudiera robar completamente inadvertido y sin peligro ninguno. La misma persona, en cambio, sólo observará por regla general, cuando sea obligada a ello, aquellos preceptos que desapruebe por ser contrarios a su convicción moral, como —por ejemplo— algunos relativos a impuestos o al inquilinato forzoso. Sin ningún escrúpulo moral, buscará en este caso, en la ley, algo que le permita eludir su cumplimiento. Sin el menor remordimiento, ocultará a las autoridades determinados hechos o hará manifestaciones falsas en su declaración de impuestos, en tanto que seguramente condenaría como fraudulenta una conducta similar respecto de un cliente. Más aún, en determinadas circunstancias y aunque la disposición no le afecte directamente y —por tanto— no entre en juego su egoísmo, aconsejará a sus amigos que eludan la ley y les prestará su apoyo.

De lo expuesto se desprende que el individuo puede adoptar una doble actitud frente al llamado derecho positivo, frente a las leyes y convenios estatales, *etc.*, en cada caso de aplicación concreta: o las aprueba y las vive en cada caso individual de aplicación como un deber, como una presión interna de su conciencia o del sentimiento jurídico, en cuyo caso son para él derecho, aunque no las observe; o falta esta aprobación interna, en cuyo caso son para él *tan sólo* fuerza, aunque se doblegue ante ellas. No existe una tercera actitud.

De las consideraciones anteriores se desprende que sólo existe un deber. *Derecho y moral, concebidos ambos como un deber en oposición al acontecer, son una y la misma cosa. Son la totalidad de las vivencias del deber; son el deber concebido unitariamente.*

A ello obedece que la *conciencia y el sentimiento jurídico*, en el sentido de una fuente creadora de supremos valores autónomos, *sean una y la misma cosa. Son la facultad, irreductible a leyes causales y sólo concebible metafísicamente, de vivir un deber. Son el deber potencial del individuo.*

La unidad de derecho y moral no es afectada por los llamados conflictos entre ésta y aquél.

Debemos distinguir los conflictos entre deber y necesidad, de los conflictos entre deber y deber.

En un conflicto entre deber y necesidad se encontraba —por ejemplo—, durante la guerra del Ruhr, el habitante alemán que era fiel a su patria, cuando consideraba las leyes alemanas como un deber y las disposiciones francesas, contrarias a ellas, tan sólo como una necesidad, como una fuerza. En situación semejante se encontraba y se encuentra el legitimista, el partidario del antiguo régimen, frente a un golpe de Estado realizado con éxito o frente a una revolución triunfante. Lo mismo sucede a quien en su más profunda convicción moral se siente obligado a un duelo, y —por tanto— desaprueba, considerándola como coacción injusta, la prohibición legal que se opone al mismo.

Tratándose de las convicciones que se presuponen en estos ejemplos —y, bien entendido, sólo tratándose de ellas— *luchan de un mismo lado el derecho autónomo y la moral y, del otro, la fuerza. No existe un conflicto entre derecho autónomo y moral.*

Pero también hay conflictos entre deber y deber, esto es, conflictos en los que existen dos o más posibilidades de conducta impregnada de valor. Piénsese —por ejemplo— en la situación en que se encuentran durante una lucha entre el Estado y la Iglesia, quienes se sienten obligados frente a ambos legisladores, *verbi gratia* un obispo católico de Prusia fiel a la ley y a la patria, durante la Lucha Cultural.

Otro ejemplo lo brinda el empleado veraz, que sólo cree poder salvar mediante una mentira el secreto oficial que se le confió.

Un tercer ejemplo: si un ministro de alguno de los Estados que están interesados en el sostenimiento del tratado de paz, estudiase con seriedad y profundidad verdaderamente científicas y partiendo de los resultados efectivos más importantes de las investigaciones actuales, el problema de la culpa de la guerra, se vería envuelto, a causa de semejante imprudencia, en un conflicto parecido, como ya deben reconocerlo en la actualidad muchos miembros de esos Estados.

En todos los ejemplos de esta segunda especie luchan el deber contra el deber, la obligación contra la obligación. *Pero nada nos autoriza para afirmar que de un lado luche precisamente el derecho y del otro precisamente la moral.* Con toda claridad se demuestra esto en el ejemplo de la lucha entre el Estado y la Iglesia. ¿De qué lado se encontraría aquí el derecho y de qué lado la moral? En otras palabras,

¿a qué partido debemos reprocharle injusticia y a cuál inmoralidad? Las mismas consideraciones valen también para los demás casos imaginables. Tan pronto como entendamos bajo la palabra «derecho» no la necesidad, la fuerza, sino un deber autónomo, la diferencia entre moral y derecho se convierte en una inútil disputa de palabras. Así —por ejemplo— se puede, si se quiere, designar el deber del empleado de decir la verdad como deber jurídico o considerar como moral su actitud respecto del secreto oficial.

En realidad, los conflictos entre deber y deber no son otros sino los que ya en la actualidad consideramos como conflictos internos de la moral, o morales. Estos conflictos son resueltos por el mismo legislador que ha creado el conflicto, por el individuo mismo. Él es el único que puede resolver, dentro de su propia conciencia, qué valor, qué deber, qué obligación es la más elevada. *Por tanto, tampoco aquí se pone en duda la unidad de la moral y del derecho autónomo.*

La unidad de derecho y moral nos ofrece una imagen notoriamente más sencilla de determinados procesos sociales, que la que teníamos hasta ahora.

Todas las relaciones de poderío en la sociedad humana pueden fundarse de dos maneras: en una necesidad o en un deber.

En cuanto se apoyan en una necesidad, son fuerza, aun en el caso de que se llame «derecho» a esa fuerza. En cambio, en cuanto significan un deber, son independientes de toda fuerza; son legislación autónoma de la personalidad moral; *son moral y derecho al mismo tiempo.*

No existe una tercera solución. Por eso no existe ningún «derecho natural», ningún «derecho justo», ninguna «justicia», distintos del deber autónomo ético jurídico, y por eso no existe tampoco un derecho incorrecto, injusto, inmoral, una moral injusta, una justicia inmoral, etc.

En el terreno del deber no es posible tampoco establecer ninguna diferencia entre el derecho «como es» y «como debía ser,» entre «lex lata» y «lex ferenda,» entre dogmática y política jurídicas. Cuando hablamos del derecho «como es,» de la *lex lata*, nos referimos generalmente a preceptos heterónomos que son observados y aplicados efectivamente —por tanto— a relaciones causales de poderío, a la necesidad condicionada, a la fuerza, al llamado derecho «positivo,» no a ningún deber. A veces también, cuando se contraponen la *lex lata* a las propias convicciones, de *lege ferenda*, se entienden bajo *lex lata* los juicios de valor de los demás, que se aceptan como un hecho dado y sobre los cuales se ejerce la crítica. En el mundo de mi deber, en cambio, no existe ninguna oposición entre lo que debo y lo que debería deber, ningún deber elevado a la segunda, a la tercera o a la cuarta potencias. Una conducta o es objeto de un deber o no lo es, pero no es posible tener el deber de tener un deber.

En cambio, quien emplea inversamente palabras como *lex ferenda*, derecho natural, derecho justo, quiere casi siempre designar con ello la aplicación de un criterio axiológico autónomo a medidas reales o imaginarias de la fuerza o al sentimiento jurídico de los demás.

Correspondiendo a la unidad de derecho y moral, la ciencia del derecho tiene, del mismo modo que la ciencia de la moral, una doble tarea.

O es ciencia causal, en cuyo caso debe tratar todo, incluso el llamado derecho positivo, con un criterio estrictamente causal, renunciando a todo juicio de valor y colocándose en cierto modo, más allá del bien y del mal; o aspira a emitir juicios de valor, en cuyo caso es al mismo tiempo ética imperativista y filosofía del derecho o —en otras palabras— ciencia unitaria del deber unitario.

En cambio, la dogmática jurídica actual, llamada positivista, se preocupa, a pesar de la admirable agudeza de sus deducciones lógicas, por un problema que, según sus propios postulados, es insoluble: se propone derivar del poder, derecho; de la fuerza, obligaciones; de la causalidad, deberes.

En realidad, los resultados de la dogmática jurídica positivista que —como es preciso subrayar— tienen un gran valor, formulados correctamente desde el punto de vista del método, deben considerarse como hipótesis o suposiciones condicionadas, que se valen de la llamada deducción jurídica como de un medio auxiliar. Son hipótesis en doble sentido.

En primer lugar, son hipótesis sobre una necesidad condicionada, porque intentan predecir cómo juzgarán los tribunales y las autoridades administrativas. Por tanto, dan efectivamente a la ciencia causal del derecho sólo un medio auxiliar; a la práctica, empero, le procuran reglas técnicas, instrucciones para el uso del orden jurídico, comparables metódicamente con las instrucciones para el empleo de una mercancía; consejos para el abogado, el notario, el comerciante, el industrial, pero también para el delincuente.

Quando el autor positivista expone solemnemente estas reglas técnicas, estas instrucciones prácticas, como si fueran un deber, tratando con ello de indicar a la práctica de los tribunales y de las autoridades cómo debe *juzgar*, se le escapan inadvertidamente mandamientos de su sentimiento jurídico subjetivo, porque de ninguna otra parte podría obtener un deber.

En consecuencia, cuando cree anunciar un derecho positivo objetivo, expone, casi siempre sin crítica ninguna, sus concepciones subjetivas. En el sentido de mis explicaciones, para que pudiese enseñar por lo menos algo relativamente objetivo sobre el deber, tendría que investigar si —y hasta qué punto— sus juicios de valor son compartidos por los demás, y construir hipótesis fundadas sobre el resultado. Éste es el segundo punto de vista, desde el cual las deducciones dogmático-jurídicas pueden tener importancia como hipótesis. Así debe entenderse por regla general la dogmática jurídica en los fundamentos de las sentencias judiciales y de las resoluciones administrativas.

Con esta dogmática positiva que cree poder deducir deberes de la fuerza, tiene que caer también *la doctrina de la llamada omnipotencia del legislador*.

Todos están de acuerdo en que, en sentido causal, nadie es omnipotente. Pero para el planteamiento imperativista del problema *no existe ningún legislador heterónomo, por tanto tampoco ningún*

legislador heterónimo omnipotente, sino únicamente un deber autónomo. Y éste no es de ningún modo «omnipotente» porque no puede ordenar algo distinto de aquello que es vivido efectivamente por la conciencia o el sentimiento jurídico.

Lo que la dogmática positivista llama omnipotencia formal del legislador, o sea su competencia para prescribir todo lo imaginable, no es en realidad más que la posibilidad causal, de que disfruta quien detenta el poder, de dictar cualesquiera órdenes. Claro es que en el concepto de competencia del legislador va implícita la afirmación de los juristas de que estas órdenes son «obligatorias» para todos en cuanto a la pena y la ejecución. Pero precisamente en esto estriba el error. Debemos más bien preguntar siempre: primero — causalmente — si las órdenes son observadas y ejecutadas de una manera efectiva; y segundo — normativamente — si las mismas son vividas realmente como deber, como derecho, y por quién.

Sólo si afirmamos lo primero son, para aquel a quien quieren someter, una necesidad condicionada, una fuerza; son lo que se llama derecho positivo. Sólo si se afirma lo segundo son, para aquel que vive el deber, derecho autónomo, verdadero. *Si no se da ninguno de ambos casos, las órdenes del legislador no son otra cosa que palabras vacías o papel impreso.*

En consecuencia, ni en uno ni en otro sentido hay la menor huella de omnipotencia. Empero, la fe positivista en la omnipotencia del legislador ha causado mucho daño. A ella se debe que los detentadores del poder, que en su mayor parte no sienten ya por encima de sí mismos, como antaño, las férreas leyes de un derecho divino, canónico o natural, piensen que pueden dar órdenes sin ton ni son y disponer lo que les plazca.

El mal se ha generalizado. Sin duda en todos los países se quejan los miembros de los más diversos partidos de la elaboración en masa de leyes arbitrarias. Pero entre los engendros de esta locura de la omnipotencia del legislador no hay que contar únicamente muchas leyes «soberanas», sino también los convenios estatales «soberanos», como los tratados de paz. Citar ejemplos resulta evidentemente innecesario.

Frente a la arbitrariedad del legislador, a la dogmática positivista no le queda — como es sabido — más que la alternativa entre

la ciega obediencia del esclavo y la negación absoluta de la competencia del legislador; por tanto, la negación del derecho y del Estado, la anarquía.

Nosotros, en cambio, hemos visto cómo la conciencia y el sentimiento jurídico resuelven, en cada caso individual de aplicación, sobre el valor o desvalor de aquello que el legislador exige. *Los súbditos y la ciencia del derecho no son esclavos del legislador sino sus jueces, quienes, aun en el caso que tengan que doblegarse ante la fuerza externa, son los llamados a resolver, en cada momento nuevamente, si aquello que les ha mandado dicha fuerza es bueno, es decir, moral y jurídico a la vez. De aquí que el deber autónomo, como premisa suprema de la deducción imperativista, ética y jurídica al mismo tiempo, esté situado, desde el punto de vista normativo, por encima del Estado y de su legislación positiva, que no es otra cosa que su criatura y el instrumento de sus exigencias de poderío.*

De este modo los preceptos heterónomos del llamado derecho positivo, las leyes, decretos, convenios estatales, etc., nos presentan un nuevo aspecto. Hasta ahora sólo los habíamos conocido como declaraciones sobre una necesidad causal condicionada, sobre la imposición de la coacción y la pena. Pero, en una medida cada vez más creciente, son también algo distinto: *son el material intelectual o, hablando metafóricamente, proyectos y ofertas que los legisladores dirigen a los demás solicitando para ellos la aprobación ético-jurídica.*

Los conceptos del llamado derecho positivo constituyen —por tanto— el medio más importante para obtener, en un círculo más o menos amplio, una objetividad, por lo menos relativa, del derecho autónomo, y solicitar la aprobación no de un individuo aislado, sino de la mayoría de los afectados por el precepto. De este modo, una gran parte de nuestro llamado derecho positivo podría considerarse, en un sentido objetivo supraindividual, como derecho verdadero y autónomo, siempre y cuando sea aprobado actual y potencialmente por una mayoría seria y poderosa; es decir que los preceptos positivos correspondan a aquello que los individuos viven como deber en los negocios de la vida diaria, como la compraventa, el arrendamiento, etc., o siempre y cuando los individuos estén dispuestos, en caso de un conflicto con el propio sentimiento jurídico, a sobreponer la sabiduría del legislador y de las autoridades al sentimiento propio.

Ahora bien, el legislador tiene un camino para obtener la aprobación ético-jurídica de los súbditos, que no debemos pasar por alto.

Se trata del engaño intencional o fortuito, de la desviación consciente o inconsciente del sentimiento jurídico.

Probablemente en todos los Estados se han dado tales casos. Recordemos —por ejemplo— la ficción, que nos fue impuesta por el legislador, de que el marco de papel era equivalente al de oro, en aquella época en que la masa aceptaba todavía de buena fe el marco de papel en lugar del marco oro. Sería —por tanto— indebido, criticar estas cosas tan sólo en relación con un Estado o con un grupo de Estados. Sobre todo durante la guerra, se trabajó en ambos lados con cierta desviación del sentimiento jurídico y no debe, por tanto, sorprendernos que estos métodos desempeñen también un papel en la continuación de la guerra después de la guerra. No debe —por lo mismo— interpretarse como deseo de dirigir reproches unilaterales, el que mencione expresamente aquel ejemplo que por su tamaño gigantesco sobrepasa a todos los demás y es único en la historia y en la sociología jurídicas. Me refiero a las ficciones y falsedades con que se ha tratado de presentar como «justos» los tratados de paz de 1919. Así, sobre todo, la ficción de que Alemania es la culpable de la guerra; o la ficción de que Austria-Hungría haya querido desencadenar la Guerra Mundial con su desafortunado ultimátum dirigido a Serbia; o la afirmación de que las fronteras estatales de 1919 son el resultado de una autodeterminación, como se enseña en ciertos tratados franceses de historia; o —por último— el aserto de que precisamente el pueblo alemán sea incapaz de administrar colonias, etc.

Una campaña intelectual gigantesca, llevada en muchos casos con la mejor intención, trata de engañar y mantener en error a la conciencia y al sentimiento jurídico de cientos de millones de hombres, frente a dichos asertos. La escuela y la prensa de los más diversos países, principalmente, trabajan en este sentido, sin darse cuenta de ello en la mayoría de los casos. En la misma dirección actúan infinidad de medidas de la más diversa índole, como, por ejemplo, la designación propagandista de la contribución de la guerra como «deuda de reparación», como «mandato»; o la prohibición de nombres inveterados y con profunda raigambre en el sentimiento jurídico de las masas, como el de «Austria Alemana» en el tratado de paz de San Germán, el de «Tirol» en Italia y el de «Bohemia Alemana» en Checoslovaquia.

Este problema de la desviación del sentimiento jurídico es —en mi opinión— uno de los más graves, más difíciles y más importantes de las ciencias del derecho y del Estado, aunque, por desgracia, no haya sido, hasta la fecha, percibido y apreciado en su plena significación. En mi sentir, coloca a la ciencia y a la administración estatal, en cuanto ésta se ocupa de educación e ilustración, frente a problemas nuevos. Tratarlos aquí sería imposible. Pero, independientemente de ellos, vale la regla general de que el derecho y el Estado son juzgados por aquellos a quienes oprimen con sus mandatos.

Pero, ¿acaso esta doctrina de la autonomía del derecho que hoy he tenido el honor de exponer, no significa arbitrio individual ilimitado e incontrolable, disolución de todo orden jurídico y estatal; en suma, anarquía?

De ninguna manera. *Precisamente la concepción anterior de que el derecho es heterónomo, de que es voluntad extraña, conduce a la anarquía si se la piensa consecuentemente hasta el final.*

La práctica política de todos los pueblos y épocas ha escapado —hasta ahora— a esta fatal consecuencia, principalmente, porque en alguna forma se ha apoyado el derecho y el Estado en recompensas y castigos ultraterrenos. Desde la deificación de los antiguos déspotas hasta las modernas doctrinas de la gracia de Dios y todas aquellas que consideran el patriotismo y la sumisión a las autoridades seglares como deber religioso, se ha fundado siempre en la religión la exigencia de la obediencia frente al derecho «positivo» heterónomo. Y cuando en la época de la Ilustración, grupos de personas cultas volvieron por primera vez la espalda a la religión, *Voltaire* acuñó la famosa frase: «Si no existiese Dios, habría que inventarlo.»

Ahora bien, la importancia de las diferentes religiones es —todavía en la actualidad— inmensa, y tal vez atravesen en estos momentos, entre nosotros, por un período de crecimiento, aunque a veces se desconozca su influencia. Sin embargo, la ciencia tiene que declarar, sin consideraciones de ninguna especie y con la franqueza a que está obligada, que actualmente ya no es posible fundar el derecho y el Estado sobre la fe en recompensas del más allá.

Pero entonces, ¿de qué otro modo será posible inducir a los ciudadanos a la obediencia frente a una voluntad extraña?

Se ha realizado un intento audaz y magnífico de construir sobre bases materialistas y —por tanto— sin el postulado de la religión divina, una nueva ética, opuesta precisamente al anarquismo, y una nueva doctrina del derecho y del Estado. Se trata de la filosofía de la historia de Marx y Engels. Pero por muy espirituales y elevados que sean los valores morales que han sido infundidos a esta nueva ética, no es posible llegar nunca a un deber, a una obligación, si se toma como punto de partida el materialismo y la causalidad. Si todo está condicionado material y causalmente, si también los movimientos de la conciencia y del sentimiento jurídico son únicamente reacciones causales adquiridas en el curso de generaciones, entonces no encontramos en el mundo entero —que en este caso sería tan sólo el causal— absolutamente nada que pudiera impedir al individuo obrar de acuerdo con un egoísmo sin límites ni escrúpulos. El Estado se convertiría entonces en una sociedad de egoístas absolutos. Por ello no es *Marx*, sino *Max Stirner*, a pesar de los graves defectos de su libro, el representante más consecuente de la doctrina heterónoma del derecho y del Estado liberada de supuestos ideológicos. Cuando preguntan los anarquistas por qué debe uno obedecer cuando otro ordena, nada puede contestar la doctrina de la heteronomía del derecho, si no quiere recurrir al garrote y a las penas infernales. En consecuencia, la concepción heterónoma del derecho y del Estado no puede resistir a la crítica anarquista.

La doctrina de la autonomía del derecho expuesta aquí pretende, en cambio, demostrar cómo un gran número de hombres, que aparentemente crece al aumentar la cultura, es en cada momento el sustentáculo del orden jurídico y estatal, independientemente de toda creencia religiosa y de todo medio de coacción terrena; y cómo dichos hombres sustentan en parte ese orden cuando rechazan y violan el resto.

La doctrina de la autonomía del derecho no nos lleva, por tanto, a la negación del derecho y del Estado, sino a la inteligencia de su verdadera justificación: *el derecho y el Estado, y todos los detentadores del poder dentro de éste y en la comunidad internacional, tienen que luchar continuamente por conquistar la obediencia no sólo externa, sino interna y espontánea, lo mismo que la conciencia del deber y la aprobación ética de todos aquellos a quienes oprimen con sus mandatos.*

En consecuencia, *el carácter del pueblo y de la humanidad* deciden sobre la forma en que deben estar organizados el Estado y el derecho, para descansar sobre una mayoría que pueda servirles de sustentáculo: *cuanto más egoísta, tanto más poder; cuanto más consciente del deber, tanto más derecho; cuanto más cercano al animal, tanto más poder; cuanto más avanzado en la evolución ética, tanto más derecho.*

No sería posible, en el marco de estas explicaciones, penetrar más profundamente en esos pensamientos que desenvuelven ante nosotros el problema de la historia mundial. Por ello pondré sólo de relieve un punto de vista cuya importancia político-jurídica es especialmente grande.

Si el derecho y el Estado tienen que reconquistar cada día la aprobación ética y la obediencia espontánea de aquellos a quienes oprimen con sus mandatos, es evidente *que, de todas las formas de Estados conocidos hasta ahora, es el Estado nacional y su derecho nacional el que descansa sobre más sólidos fundamentos.* Porque el llamado sentimiento nacional, la conciencia popular, muy especialmente, en su anhelo de unir a todos los miembros de la comunidad en un Estado y bajo un mismo derecho, es una de las expresiones más importantes del sentimiento jurídico, quizá la fundamental. Y esto no vale únicamente para la época que se inicia en el siglo XIX —en que el sentimiento nacional hace su aparición en la conciencia de los pueblos como una fuerza que actúa independientemente—, sino que, desde el principio de la historia —hasta donde nosotros alcanzamos a ver— la conciencia de la comunidad popular ha sido la fuerza creadora del Estado y del derecho tal vez más importante, aunque en un principio se la haya confundido, por regla general, con la conciencia de la comunidad de fe o de la comunidad de Estado, de clase o de casta, o de cualquiera otra de índole política. Esta enorme importancia de la conciencia popular no sería superada de ningún modo en una verdadera Liga de las Naciones o en una confederación mundial de Estados. Porque también aquí el punto de gravedad de la vida jurídica cotidiana, y de las preocupaciones diarias de la administración, radicaría en los Estados confederados, por lo que su estructura nacional unitaria continuaría siendo, como en la actualidad, el centro de todas las exigencias éticas dirigidas al Estado y a la comunidad de Estados. Más aún, en el caso de que intentásemos representarnos un Estado mundial unitario, mientras todos los

habitantes de la tierra no hablen un idioma común, ni tengan las mismas costumbres y un sentimiento jurídico unitario, no podríamos imaginarlo de manera distinta que en la forma de una superestructura, construida sobre provincias nacionales limitadas, con amplísima autonomía administrativa y amplísima libertad para la formación de un derecho particular nacional. Por consiguiente, el problema nacional no perdería un ápice de su importancia ético-jurídica con la organización del mundo, fuese cual fuese la amplitud de ésta, así como no ha perdido actualmente su importancia ético-jurídica en el interior de Suiza o de Checoslovaquia.

En consecuencia, uno de los mayores errores, que muchos cometen, consiste en considerar el sentimiento nacional como un punto de vista superado, o en querer educar a los hombres conforme a una ética que lo condena como desvalor. Así como los sentimientos del amor y de la pertenencia a la familia no pueden parecernos en el pasado histórico o en un futuro previsible algo superado o reprobado por el juicio ético de los pueblos, así tampoco podemos afirmar lo mismo respecto del sentimiento del amor y de la pertenencia al propio pueblo. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el curso de la historia, no podemos imaginarnos ningún vínculo más sólido para unir a un grupo de hombres en forma duradera, contra todos los golpes del destino, bajo un mismo derecho y un mismo Estado, que la conciencia de la comunidad natural y moral, que la *conciencia popular*. Formaciones estatales artificiales cuyas fronteras han sido trazadas por el arbitrio de un déspota o por el sable de un dictador, sobre pueblos enteros o a través de los mismos; Estados en los que por esta sola razón una gran parte de la población se doblega tan sólo ante la fuerza y no tiene en el corazón otro sentimiento para la llamada patria que el odio y el desprecio, aunque no pueda demostrarlo abiertamente; Estados como éstos, descansan sobre los fundamentos más inseguros y deleznales, aunque aparentemente disfruten de una situación económica favorable y ostenten cierto brillo exterior.

En cambio, precisamente el destino de Alemania en los últimos años, o acontecimientos como la adhesión unánime de los austro-alemanes y bohemio-alemanes al Estado Alemán el día 12 de noviembre de 1918, pocos días después de la catástrofe, demuestran las enormes fuerzas psíquicas de que dispone el Estado nacional, aun en el instante de la mayor desgracia y de la más profunda humillación.

Por tanto, *la doctrina de la autonomía del derecho*, muy lejos de conducir a la anarquía, nos demuestra que el *Estado* y el *derecho*, que hasta ahora habían brotado en gran parte, en una forma salvaje y anárquica, de las necesidades momentáneas de los detentadores del poder y que, por tanto, habían estado amenazados por la desobediencia, la revolución y la *anarquía*, en vez de fundarse sobre la *retribución en el más allá* y la *coacción terrena*, deben construirse, en forma cada vez más amplia, sobre la *conciencia* y el *sentimiento jurídico* de los ciudadanos o, por lo menos, de una mayoría resistente y lo más numerosa posible de ellos.

La fuerza por sí sola no lo logra. Porque, como es sabido, con las bayonetas se puede hacer todo, menos sentarse en ellas. *También frente a un bandido practicaré la «política de cumplimiento», mientras esto signifique para mí el mal menor. Pero cumplimiento «leal» de acción voluntaria por deber y sin coacción, lealtad hacia leyes y convenios, sólo se dan en ese mundo en que no existe el llamado derecho del más fuerte y del vencedor, en el mundo del deber, de la auto- legislación ética.*

En consecuencia, la tarea de la ciencia estriba en enseñar a los detentadores del poder, en todos los pueblos y en todos los Estados, *que el derecho no está en las leyes y convenios de papel, ni tampoco en las penas de la cárcel y el infierno, sino en la moral, en el corazón de los hombres.*

DERECHO Y MORAL,
de RUDOLF LAUN, se imprimió
en la República Argentina en diciembre de 2020.